

論行政訴訟訴訟和解之效力*

張文郁**

目次

- | | |
|-------------------|---------------|
| 壹、訴訟和解之概念、目的和性質 | 二、關於訴訟標的之各種學說 |
| 貳、訴訟和解之要件 | 三、小結 |
| 一、訴訟法之要件 | 肆、訴訟和解之效力 |
| 二、實體法之要件 | 一、關於訴訟程序之效力 |
| 三、法官應負審查義務 | 二、「準確定判決」之效力 |
| 參、訴訟和解之標的 | 伍、結語 |
| 一、訴訟和解之標的與訴訟標的之關係 | |

* 非常感謝吳庚老師對我的提攜，謹以此文紀念老師，聊表寸意。
〔責任校對：廖翊婷〕。

** 國立臺北大學法律學系教授。
穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/82010102.pdf>。



壹、訴訟和解之概念、目的和性質

所謂和解，依民法之概念，係指當事人兩造以相互讓步之方式解決紛爭之契約（民法第736條參照）。而行政程序法第136條則規定：「行政機關對於行政處分所依據之事實或法律關係，經依職權調查仍不能確定者，為有效達成行政目的，並解決爭執，得與人民和解，締結行政契約，以代替行政處分。」和解係當事人解決行政實體法權利義務爭議之手段，若行政程序法允許當事人得互相讓步，締結和解契約以終止爭執，則於行政訴訟上亦應允許當事人自行和解而放棄由法院作出判決解決爭議之請求，是以訴訟和解不僅在於解決當事人之實體爭執，主要亦在於終結當事人之訴訟關係¹。德國行政法院法於1990年第四次行政法院法修正法（das 4. VwGOÄndG）通過時，於第106條增設訴訟和解之制度，允許當事人得於法院、受命或受託法官之前締結和解²。藉由訴訟和解之制度，當事人得以平和方式迅速解決紛爭，避免調查舉證困難、程序繁瑣、耗費龐大且結果難以預知之行政訴訟程序，以求減輕法院之負擔、儘快解決當事人之爭議並確定其權利義務關係，是以我國行政訴訟法（以下簡稱本法）第219條以下明文規定承認訴訟和解制度。

本法第219條規定：「I. 當事人就訴訟標的具有處分權且其和解無礙公益之維護者，行政法院不問訴訟程度如何，得隨時試行和解。受命法官或受託法官，亦同。II. 第三人經行政法院之許可，得參加和解。行政法院認為必要時，得通知第三人參加。」訴訟和解之承認乃是適用處分權主義之結果，職是之故，不論是民事訴訟抑或行政訴訟，當事人須對訴訟標的具有處分權，若無，則不得締結

¹ Vgl. Othmar Jauernig/Burkhard Hess, Zivilprozessrecht, 30. Aufl., 2011, § 48 I.

² Vgl. Wolf-Rüdiger Schenke, in: Kopp/Schenke (Hrsg.), Verwaltungsgerichtsordnung, 20. Aufl., 2014, § 106 Rn. 1.

訴訟和解。

稱訴訟和解者，謂當事人於訴訟繫屬中，在受訴法院、審判長、受命法官或受託法官之前³，就訴訟標的以終結訴訟並解決實體權利爭執之意思，互相讓步而締結之訴訟契約⁴。據此定義，訴訟和解主要具有兩項作用，其一為終結訴訟關係，其二則為當事人合意解決其爭訟之實體權利爭議。由於前者涉及訴訟關係，具有訴訟法之性質，而後者則針對實體權利、義務，是以具有實體法之性質，職是之故，依實務及通說之見解，訴訟和解係同時具有實體法及訴訟法二元性質（Doppelnatur，或譯為雙重或兩面性質）之行為，一方面為當事人以訴訟行為成立之訴訟契約，訴訟上之主要法律效果乃是使訴訟繫屬不經法院裁判而終結，並發生法定效力，另一方面則以實體法之和解契約（行政法之和解契約）終止其爭執並創設、消滅當事人間之實體權利義務⁵。又依第222條之規定：「和解成立者，其效力準用第213條、第214條及第216條之規定。」因此，訴訟和解成立後，於當事人之間將發生準確定判決之效力⁶。

貳、訴訟和解之要件

訴訟和解之締結須具備之要件可依訴訟面和實體面區分為二，以下分別敘述之。

3 德國行政法院法於1990年修正第106條時，甚至允許法院或法官於書面審理程序以書面建議當事人和解。

4 參見陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（中冊），修訂4版，頁558（2005年）。

5 Vgl. Jauernig/Hess (Fn. 1), § 48 I Rn. 4.

6 行政訴訟法第222條規定：「和解成立者，其效力準用第213條、第214條及第216條之規定。」

一、訴訟法之要件

(一) 須當事人適格

德國實務通說並不認為當事人適格係訴訟和解之要件，蓋因其效力與實體判決無關⁷。然而，由於本法第222條規定，當事人成立訴訟和解時，就該和解之訴訟標的發生「準確定判決」之效力，此乃訴訟和解之重要訴訟法法律效果，實體法之和解並無此種效力，職是之故，訴訟和解之第一要件乃是和解之當事人須具備當事人適格之要件，適格之當事人因享有訴訟實施權，原則上就訴訟標的始能於訴訟上適法處分，若當事人不適格，原則上其就該案件之訴訟標的即欠缺法律上之利害關連性而無訴訟實施權，因而就訴訟標的亦無處分權，法院應立即裁定駁回，於此種情形原則上無法成立訴訟和解，若成立和解，應屬於訴訟外之和解。

當事人以外之第三人是否得參與訴訟和解，原本眾說紛紜，往昔通說認為不許，然而為擴大和解解決紛爭之功能，本法第219條第2項規定，當事人⁸以外之第三人亦得參與訴訟和解，此外，訴訟和解之客體亦可包括訴訟標的以外之權利義務，蓋因參與訴訟和解之人既不限於當事人兩造，則成為訴訟和解之客體只須包含訴訟標的即可，不限於訴訟標的⁹。

依本法第219條第2項規定，第三人經法院之許可，得參加和解。法院認為必要時，亦得通知第三人參加。然而，若深入觀察，應可得知當事人相互間所締結之訴訟和解與當事人以外之第三人參與訴訟和解不但性質不同，而且法律效果亦有差異。由於當事人相互間存在訴訟法上之權利義務，特別是因訴訟繫屬所生對於法院之

⁷ Vgl. Jauernig/Hess (Fn. 1), § 48 III Rn. 11.

⁸ 此之當事人依本法第23條規定，包括第41條和第42條之參加人。故第三人應不包括此等參加人。

⁹ Vgl. Jauernig/Hess (Fn. 1), § 48 II Rn. 8, 9.

裁判請求權，此乃原告、被告及特定參加人（本法第41條、第42條規定）之訴訟上權利，當事人和訴訟外之第三人相互間並不存在因訴訟繫屬而發生，須以裁判終結之訴訟法律關係，因而並無締結訴訟和解以終結訴訟關係之必要性。職是之故，第三人之參與和解，嚴格言之，係附加於當事人之訴訟和解，本質上應無二元性質而僅為實體法之和解契約。職是之故，原告與被告未成立訴訟和解時，法院、受命法官或受託法官不應為原告或被告一方和訴訟外之第三人成立和解。

當事人以外之第三人參加訴訟和解者，就該法律關係雖可作為執行名義，然而不生準確定判決之效力，本法第227條第1項規定：「第三人參加和解成立者，得為執行名義。」由於其非真正之訴訟和解，是以與當事人締結之訴訟和解效力有別。是以此種和解僅為廣義之訴訟和解，並非真正之訴訟和解，兩者於性質上及效力上皆有差異。

（二）須當事人有訴訟能力

締結訴訟和解須由當事人為訴訟行為，因此當事人須具有訴訟能力始可，無訴訟能力人原則上應由其父母作為法定代理人共同代理（本法第27條、第28條準用民事訴訟法第47條）¹⁰。若由無訴訟能力人締結之訴訟和解，即不生效力¹¹，但得由法定代理人追認之（準用民事訴訟法第48條）。由於締結訴訟和解屬於特別委任之事項，是以如由訴訟代理人締結者，該訴訟代理人須有特別委任（本法第50條第1項但書參照）。

¹⁰ Vgl. *Jauernig/Hess* (Fn. 1), § 48 III Rn. 11.

¹¹ Vgl. *Harald Geiger*, in: *Eyermann/Fröhler* (Hrsg.), *Verwaltungsgerichtsordnung*, 11. Aufl., 2000, § 106 Rn. 24.

(三) 須於訴訟繫屬中在受訴法院、受命法官或受託法官之前
訂立

訴訟和解顧名思義須在訴訟繫屬中，由受訴法院、審判長、受命法官或受託法官介入，若當事人之和解不符合此項要件，即非訴訟和解，而應屬於訴訟外之和解（實體法之和解）。至於訴訟是否合法並非訴訟和解之要件，因此，縱使原告之起訴不合法，若當事人就訴訟標的得合法處分者，在法院駁回原告之訴前，皆可成立訴訟和解。德國文獻上有認為，縱使法院欠缺管轄權或審判權，亦不妨礙當事人成立訴訟和解，甚至法院組織不合法之情形，亦同¹²。從德國文獻之見解可推出，只要由當事人在法官之前締結和解，皆可認為成立訴訟和解，不論承辦和解之法官是否有權就該案件進行實體審判。拙見認為，此見解應是因德國法規定，訴訟和解主要在於終結訴訟，並結束實體爭議，而訴訟和解之效力僅於和解內容適於強制執行時，得作為執行名義，並無「準確定判決」之效力。然而，由於我國法之規定與德國法有異，亦即訴訟和解之效力準用確定判決之效力（本法第222條參照）¹³，因此，拙見認為，欠缺審判權時，法院仍應依法將案件移送於有審判權之法院，不應為當事人成立訴訟和解，若不顧審判權之欠缺而替當事人成立訴訟和解者，訴訟契約之部分應屬無效，僅能認為具有實體法之和解效力。若原告起訴之案件訴訟繫屬已消滅，原訴訟當事人即無成立訴訟和解之可能。職是之故，法院作出終局判決確定後，當事人始成立訴訟和解者，不屬於訴訟和解。判決確定前，當事人成立訴訟和解者，和解前之法院判決應即失效。

¹² Vgl. *Carl Hermann Ule*, *Verwaltungsprozeßrecht*, 9. Aufl., 1987, § 44 II; *Eyermann/Geiger* (Fn. 11), § 106 Rn. 3, 20; *Jauernig/Hess* (Fn. 1), § 48 III Rn. 15; BGHZ 35, 309 (310).

¹³ 就和解之效力，參見下述肆。

（四）當事人須對和解標的互相讓步

訴訟和解既稱為和解，包含實體與訴訟之性質，即應符合實體和解之要件，參酌民法第736條之規定，當事人不但須對訴訟標的享有處分權或管理權，並須互相讓步始可。所謂讓步係指當事人放棄任何訴訟上可能獲得之最有利結果，實體法或訴訟法上有利法律地位之放棄皆屬於讓步。且所為之讓步不須完全針對訴訟標的，亦可包含民事法或其他訴訟標的外之權利義務¹⁴。當事人亦得約定本案應依其他類似案件之判決結果判決，而以之作為訴訟和解之內容¹⁵。當事人之讓步不須相當，若一方全無讓步，則不能成立和解¹⁶，由當事人一方就訴訟標的全部讓步之情形應屬於捨棄或認諾¹⁷。由於和解之成立須有讓步，故屬於不利行為，是以在必要共同訴訟，須全體共同訴訟人皆同意和解，始能有效成立。

（五）須製作和解筆錄

依本法第221條第1項之規定，當事人成立訴訟和解時，法院、審判長、受命法官或受託法官應請書記官為之製作和解筆錄。此項要件應認為係訴訟和解應遵守之方式，違反之者，訴訟和解不成立，僅生實體法和解之效力¹⁸。若當事人聲請，法院並應准許當事人閱覽筆錄或向當事人朗讀，若無正當理由拒絕當事人閱覽筆錄或向當事人朗讀，則因當事人之真意未確定，應認為該和解不生效力（本法第221條第2項準用第130條）。

¹⁴ Vgl. Ule (Fn. 12), § 44 I; Eyermann/Geiger (Fn. 11), § 106 Rn. 2, 8.

¹⁵ Vgl. Peter Kothe, in: Redeker/von Oertzen (Hrsg.), Verwaltungsgerichtsordnung, 15. Überarbeitete Aufl., 2010, § 106 Rn. 4.

¹⁶ Vgl. Eyermann/Geiger (Fn. 11), § 106 Rn. 8, 13; Jauernig/Hess (Fn. 1), § 48 II Rn. 10.

¹⁷ Vgl. Eyermann/Geiger (Fn. 11), § 106 Rn. 2.

¹⁸ Vgl. Kothe (Fn. 15), § 106 Rn. 8.

二、實體法之要件

訴訟和解因同時具有實體法和解之性質，因此，訴訟和解之標的必須符合行政程序法第136條關於和解契約之要件，特別是不得違背強制禁止規定及公序良俗並確認當事人約定之給付內容適宜強制執行。此外，法院並應確認當事人就訴訟標的確有處分權且其和解無礙於公益之維護，茲就此等要件略述如下。

(一) 對訴訟標的有處分權或管理權

訴訟和解乃處分權主義之結果，訴訟和解之客體主要係針對訴訟標的¹⁹，並因此創設、變更、消滅當事人間實體法之權利義務關係，此外更將直接導致訴訟終結，是以當事人須對訴訟標的具有處分權或管理權始能締結訴訟和解。若當事人就訴訟標的並無處分權或管理權，該等案件即無成立訴訟和解之可能，縱使締結和解，亦不生效力²⁰。判斷當事人對於訴訟標的是否有處分權或管理權，原則上以當事人是否得合法就訴訟標的訂立實體法之和解契約為準。據此，依本法第219條第1項規定，首先，所有當事人就訴訟標的須有處分權或管理權，始得締結訴訟和解。蓋因和解係針對訴訟標的之處分，若當事人無管理或處分權，不可能締結有效之和解契約，則和解之目的即無法達成。然而，實務上如何判斷當事人就訴訟標的有無處分權，實屬困難之問題。

就人民而言，若其依法可享有之權利，不論是公法或私法，除非法律別有規定外，否則應有處分權。在民事法領域之權利，例如民法、專利法、商標法等等，除非有法律之特別規定（例如破產法

¹⁹ 文獻上，葉百修、張宏誠，和解 § 219，收於：翁岳生、許宗力、張登科編，行政訴訟法逐條釋義，2版，頁603（2018年），認為訴訟和解之標的並非訴訟標的者，因其忽視訴訟和解終結訴訟繫屬以及具有準確定判決之效力，是以應不可採。

²⁰ Vgl. Eyermann/Geiger (Fn. 11), § 106 Rn. 24.

第75條之情形)，原則上法院不須另外認定人民是否享有處分權。在公法領域，人民是否享有權利，主要認定依據係司法院釋字第469號解釋所揭櫫之規範目的（保護規範）理論。若依原告訴請法院判決所依據之法規，其享有公法上之權利者，原則上人民亦可處分，但該權利之性質不許人民自由處分者，不在此限。

然而，在行政機關為當事人時，由於依法行政要求以及機關事務權限之限制，法院於進行訴訟和解時，負有審查其對於訴訟標的是否有處分權之義務。詳言之，和解契約之標的須屬於行政機關之事務權限，而行政機關對之有處分權，且在其土地管轄範圍²¹，若違反前者，和解契約應屬無效，違反後者原則上和緩契約有得撤銷之原因（行政程序法第111條第6款、第115條參照）。若行政機關對於為和解契約標的之事項享有裁量權時，原則上在其裁量權限內即有締結和解契約之處分權。此外，若行政機關依現行法規有做出某種類及內容行政處分之權限時，行政機關即得直接以該內容或做出該行政處分為和解契約內容和人民締結和解契約²²。雖然行政機關對於給予給付之法定構成要件是否存在不明之場合，得和人民締結和解契約承諾給予法定之給付而不認為違反依法行政原則，但若行政機關於契約內承諾依法律規定不應允許之給付者，該契約原則上應屬無效，例如建築管理機關於和解契約內承諾在依法禁止建築之區域發給建築許可²³。

21 參見陳敏，行政法總論，8版，頁589（2013年）。

22 Vgl. Ferdinand Otto Kopp/Ulrich Ramsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz, 7. Aufl., 2000, § 55 Rn. 21; Hans Julius Wolff/Otto Bachof/Rolf Stober, Verwaltungsrecht, 6. Aufl., 2001, § 54 Rn. 33; Schenke (Fn. 2), § 106 Rn. 13.

23 Vgl. BVerwGE 49, 359 (361); vgl. auch BVerwG, NVwZ 2000, S. 1285 (1285 ff.): 鄉鎮和都市建設計畫（Bebauungsplan）區外之土地所有權人訂立行政契約，約定變更（擴張）都市計畫區域，將原本非屬於都市計畫區之土地納入而改成住宅區，由於該土地所有權人本來非屬於都市計畫區之地主，原不需繳納開發受益費（Erschließungsbeiträgen），雙方約定由地主繳納一定數額之款項作為未指定目的之捐贈（於本案被作為鎮立兒童遊戲場所之維護費）取代現時已無法確定之開發受益費後，將該土地納入都市建設計畫區並發給建築許可。此項行政

(二) 和解須無礙於公益之維護

依本法第219條第1項之規定，當事人僅於不妨礙公益之情形，始得成立訴訟和解，由於公益之實現與維護乃行政機關執行行政任務之主要目的，行政機關於作出任何行為時皆須考慮對公益之影響。從行政程序法第146條第1項之規定：「行政契約之當事人一方為人民者，行政機關為防止或除去對公益之重大危害，得於必要範圍內調整契約內容或終止契約。」可以推知，既然行政機關為防止或除去對公益之重大危害，得於必要範圍內調整契約內容或終止契約，則於締結契約之時即應避免因締約而危害公益，故和解契約之締結亦不得重大違背公益²⁴。和解契約之締結既須以讓步為要件，則行政機關之讓步必須不嚴重違反公益，否則應認為不符行政程序法第136條所規定「有效達成行政目的」之要求。一般而言，若行政機關締結和解契約，特別是讓步之結果將對公眾造成不利之影響者，原則上即可認為違反公益而違法。為擔保行政機關於締結訴訟和解時不妨礙公益，法官於涉及公益之訴訟案件進行訴訟和解時，實應通知其他相關（目的事業主管）機關和利害關係人陳述意見，而且除非涉及業務秘密或其他應保密事項，否則應禁止當事人締結保密條款，不公開和解內容。蓋當事人若任意締結保密條款，則他人無從得知和解內容，則難以監督當事人之和解是否違背公共利益。

三、法官應負審查義務

關於以上事項，主持和解之法官應負有實體審查義務，蓋因訴訟和解既在法官之前作成，且具有準確定判決之效力，為避免違法

契約因違反不當連結禁止原則，且當事人承諾法所不許之對待給付，依§ 59 II Nr. 4 BayVwVfG之規定應屬無效。

24 Vgl. *Heinz Joachim Bonk*, in: *Stelkens/Bonk/Sachs* (Hrsg.), *Verwaltungsverfahrensgesetz*, 9. Aufl., 2018, § 55 Rn. 5.

和解，法官依法應審查和解之內容，而非僅單純令書記官記明筆錄。相對於鄉鎮市調解、消費爭議調解以及法院調解委員酌定之調解條款皆須經法官實質審核²⁵，是以應認為訴訟和解時，為避免和解有無效或得撤銷事由，法官亦有審核義務²⁶。理論上法官應將和解個案之當事人（特別是行政機關）有處分權以及和解不妨礙公益之認定理由扼要記明於和解筆錄，以便其後有爭訟時得以審查。

參、訴訟和解之標的

一、訴訟和解之標的與訴訟標的之關係

由於訴訟和解在訴訟上之主要效果係終結原告、被告以及法院相互間因訴訟繫屬發生之訴訟關係，並使和解之訴訟標的具有準確定判決之效力，因而訴訟和解僅能由當事人在法院、審判長、受命法官或受託法官之前針對訴訟標的而締結，換言之，訴訟和解之客體必須針對原告所起訴之訴訟標的²⁷，若就訴訟標的以外之事項成立和解，既無訴訟繫屬關係可供終結，自不發生訴訟法之效力，因其不生訴訟法之法律關係（訴訟繫屬），則該和解亦無法發生「準確定判決」之效力²⁸，其既不生任何訴訟上之作用，自與訴訟和解

25 參見鄉鎮市調解條例第26條第4項規定：「法院因調解內容牴觸法令、違背公共秩序或善良風俗或不能強制執行而未予核定者，應將其理由通知鄉、鎮、市公所。法院移付調解者，並應續行訴訟程序。」

26 不同見解，魏大曉，民事訴訟法，頁220（2015年），認為法官僅能為形式審查。

27 雖然德國之行政法院法第106條（§ 106 VwGO）之用語為和解標的（Gegenstand des Vergleiches），然而實務通說皆將之解為訴訟標的（Streitgegenstand）。Vgl. § 794 I Nr. 1 ZPO; Schenke (Fn. 2), § 106 Rn. 12; Jauernig/Hess (Fn. 1), § 48 II Rn. 9.

28 雖然立法者得立法明文規定無訴訟繫屬關係之和解亦得具有確定判決之效力，例如鄉鎮市調解委員會調解成立並經法院核定之民事案件（鄉鎮市調解條例第24條第2項），惟此處並無法律規定，故不得為相同解釋。

無關。本法於第219條第2項明文承認當事人以外之第三人得參與訴訟和解，且因準用民事訴訟法第380條之1之規定，當事人亦得就訴訟標的以外之事項成立和解，此乃為擴大訴訟和解解決紛爭之功能，容許當事人對於非屬訴訟標的，但與訴訟標的具有牽連關係之爭議事項，亦得於訴訟和解時，併同締結和解契約²⁹。惟此部分之性質應認為係實體法之和解，而非固有意義之訴訟和解。若就原告所未聲明之事項（未起訴之訴訟標的）一併進行和解時，非訴訟標的之部分必須附隨於訴訟標的始得成立和解，詳言之，當事人必須就訴訟標的之全部或一部成立和解，始能就非訴訟標的之部分同時和解，雖然書記官通常可能將非訴訟標的之和解同時記載於和解筆錄，然而其僅屬於實體法之和解而非訴訟和解。因而，若當事人於法院、受命法官或受託法官之前僅願意就非訴訟標的成立和解，法院或法官並無為其成立和解之義務，縱使為之，亦僅能認為當事人成立實體法之和解，應認為不生「得為執行名義」之效力。

二、關於訴訟標的之各種學說³⁰

行政訴訟之訴訟標的內涵為何，應依何種標準確定，不論在我國或德國，學說上向來存有爭議，一直無法獲得共識，由於我國之行政訴訟制度主要係參考德國法制，因此對於此問題有必要參考德國文獻之見解，以便尋求解答。在德國，雖然行政法院法（Verwaltungsgerichtsordnung, VwGO）和財稅法院法（Finanzgerichtsordnung, FGO）之條文有訴訟標的之用語³¹，但何謂訴訟標的，立法者無未作出定義，導致實務、學術對此概念之內涵爭論不休，由於訴訟標的之內涵迄今仍無定論，是以德國立法者於1990年

29 德國文獻上亦認為當事人得就與本案訴訟標的以外相關連之法律爭議同時締結訴訟和解。Vgl. Eyermann/Geiger (Fn. 11), § 106 Rn. 1, 21.

30 對於訴訟標的各種學說之詳細介紹參見張文郁，權利與救濟（二）——實體與程序之關聯，頁141-187（2008年）。為求本文體系之完整性，以下仍摘要介紹，並進行增修。

31 Vgl. §§ 121 VwGO; 110, 114 FGO.

修改行政法院法將起訴狀應記載訴訟標的之規定修改為記載「起訴請求之標的」(Gegenstand des Klagebegehrens)³²，然而文獻上大多認為該用語改變只是方便欠缺法律知識之民眾起訴，實際上起訴請求之標的乃是訴訟標的之另外一種表達方式而已，並無實質改變³³，由於民事訴訟較行政訴訟更早發展，其學說體系已經發展成熟，而且兩者之主要目的皆在於人民權利之維護，是以關於行政訴訟之訴訟標的，亦得藉由民事訴訟之相關學說、見解，配合行政法之特性而建立體系³⁴。以下謹針對各種主要之訴訟標的理論略加介紹。

(一) 行政處分說

有德國學者認為，撤銷訴訟之訴訟標的乃是原告訴請撤銷之行政處分，蓋原告既以該行政處分作為不服之對象而請求將之撤銷，即應以之作為訴訟標的³⁵。於我國實務，某些行政法院之判例亦採此說，例如最高行政法院52年裁字第107號判例認為：「**行政訴訟之標的，為官署基於公法所為之行政處分，不得為私人和解之標的，縱陳某一與再審原告曾有何和解，要與為行政訴訟標的之行政處分無關**」(粗體字為本文所強調)³⁶。

32 德國之行政法院法第82條亦有相同之修正。Vgl. BT Drucks. 10/3437, S. 111; Schenke (Fn. 2), § 82 Rn. 1, 7.

33 Vgl. Peter Brandis, in: Tipke/Kruse (Hrsg.), Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, Stand: Lfg. März 2001, § 65 Rn. 13 ff.; Dietmar Bittner, Finanzgerichtsordnung, Stand: Lfg. 1998, § 65 Rn. 15; Roberto Bartone, in: Kühn/von Wedelstädt (Hrsg.), Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung, 19. Aufl., 2008, FGO § 65 Rn. 4; Ulrich Schallmoser, in: Hübschmann/Hepp/Spitaler (Hrsg.), Abgabenordnung/Finanzgerichtsordnung, Stand: Lfg. 2008, FGO § 65 Rn. 61; Jo Lammerding, Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung und Nebengesetze, 15. Aufl., 2005, S. 658.

34 Vgl. Steffen Detterbeck, Streitgegenstand und Entscheidungswirkungen im Öffentlichen Recht, 1995, S. 7, 22.

35 Vgl. Hangs Klinger, Verwaltungsgerichtsordnung, 1960, S. 307, 轉引自，葉百修、吳綺雲，行政撤銷訴訟之研究，頁114（1990年）。

36 相同或類似見解另見最高行政法院27年判字第28號、51年裁字第101號判例。

我國學術上採此見解者認為：「……在我國行政訴訟上，撤銷訴訟之訴訟標的，應解為係起訴聲明所請求撤銷之具體行政處分（或訴願決定）」³⁷。由於行政訴訟法有許多條文文義表明訴訟標的乃是行政處分，例如依第37條第1項第1款之用語，「為訴訟標的之行政處分係二以上之機關共同為之者……。」第197條規定「撤銷訴訟，其訴訟標的之行政處分涉及金錢或其他代替物者……。」是以若單從條文文義觀察，（撤銷訴訟之）訴訟標的似應解為係起訴聲明所請求撤銷之具體行政處分。

（二）行政處分違法說

德國學者Werner Niese認為撤銷訴訟之訴訟標的應係被非難而請求撤銷之行政處分之違法性³⁸，於德國現時關於行政法院法之文獻，幾乎已無人主張此說，然而於財稅法院法之文獻，仍有許多主張者。我國昔日亦有學者採此說，其認為撤銷訴訟之訴訟標的應係行政處分之違法性，本說認為違法性係指行政處分整體觀察之違法性，而非個別之違法事由，只要事實和法律狀態相同，應認為即使行政機關替換處分理由而為同一內容之行政處分，或反覆為變更內容之處分，皆屬同一案件，原告僅須對於權利侵害最大之處分提起撤銷訴訟即可³⁹。

（三）實體法說

1. 舊實體法說

本說主要之發展者為德國（普魯士）學者Konrad Maximilian Hellwig（1856–1913），依本說之見解，訴訟標的專以原告主張之

37 參見陳計男，行政訴訟法釋論，頁213（2000年）。

38 Vgl. Werner Niese, Über den Streitgegenstand der Anfechtungs- und Vornahmeklagen im Verwaltungsprozeß, JZ 1952, S. 353 (358).

39 參見陳清秀，稅務訴訟之理論與實務，頁116-118（1991年）。

實體法權利或法律關係作為認定之標準⁴⁰，每一個實體法之權利或法律關係在訴訟上皆構成獨立之訴訟標的，因此，縱使數個實體法上之權利，而在訴訟上皆為相同之訴之聲明（訴之聲明同一），訴訟標的亦為複數。在撤銷訴訟，有主張本說者認為，原告因行政機關作出違法侵害權益之行政處分而產生實體法上之侵害排除請求權，原告行使此權利以對抗行政機關，是以此種侵害排除訴訟之訴訟標的應係原告實體法上之侵害排除請求權⁴¹。

行政法院於其作成之判例中，亦有認為行政訴訟（撤銷訴訟）之訴訟標的為實體法之法律關係者，例如最高行政法院72年判字第336號判例認為：「為訴訟標的之法律關係，於確定之終局判決中已經裁判者，就該法律關係有既判力，……」⁴²。陳清秀教授傾向此說，其認為「本文認為傳統實體法上法律關係之權利主張說，似最能把握訴訟之目的，在解決實體法律關係之紛爭。……」⁴³。

2. 新實體法說

鑑於純粹訴訟法說具有相當之缺陷，許多學者（主要是Arthur Nikisch、Karl Larenz）主張訴訟標的之確定應回歸實體法之概念，而以實體法之規定作為認定之標準⁴⁴。但本說與舊實體法說有異，詳言之，於數實體法請求權皆本於同一事實而生，而以同一給付為

40 Vgl. Christian Seiler, in: Thomas/Putzo (Hrsg.), Zivilprozeßordnung, 32. Aufl., 2011, Einl. II Rn. 4.

41 Vgl. Wolfgang Grunsky, Grundlagen des Verfahrensrechts, 2. Aufl., 1974, § 5 IV, S. 42 f.

42 相同或類似見解尚有最高行政法院49年裁字第47號判例。

43 令人困惑者乃是陳清秀教授又認為訴訟標的之特定，可採取二分肢說之見解。若將其主張綜合，則實體法說加上二分肢說實質上即接近三分肢說。參見陳清秀，行政訴訟法，8版，頁466（2018年）。

44 Vgl. Seiler (Fn. 40), Einl. II Rn. 7; Grunsky (Fn. 41), § 5 II 1, S. 29 ff.; Walther Jakob Habscheid, Die neuere Entwicklung der Lehre vom Streitgegenstand im Zivilprozeß, in: Gottwald (Hrsg.), Festschrift für Karl Heinz Schwab zum 70. Geburtstag, 1990, S. 181 (193 f.); Detterbeck (Fn. 34), S. 43.

目的之情形，應視為僅有一實體法之請求權存在，此稱為請求權基礎競合或請求權規範競合⁴⁵，此時原告僅可視其中何者為主要（最重要）之請求權而行使之，是以其訴訟標的亦僅為一，而通常所謂之請求權競合，則是基於不同事實而生之請求權，而其給付相同者而言。亦有學者認為應以請求權支配之客體是否同一，作為判斷請求權競和或請求權基礎競合之標準，換言之，若多數請求權支配之客體不同時，即屬於不同訴訟標的⁴⁶，因本說仍將訴訟標的之認定與實體法律關係相結合，故稱為新實體法說⁴⁷。

（四）訴訟法說

德國文獻上有學者認為，實體法說違背法官知法之原則，而且訴訟標的純粹係訴訟法之概念，因而應與實體法分離。本說主張在確定訴訟標的之概念時，應將實體法之請求權排除，故所謂之訴訟標的係原告請求法院為特定內容之裁判之訴訟法上請求權⁴⁸。職是之故，若原告依同一事實訴請被告給付，縱使於實體法上有多數請求權，亦非訴之競合。此為德國之通說，法院之裁判亦趨向本說。雖然大多數學者主張訴訟法說，然而對於訴訟標的之定義卻缺乏一致之見解，又可細分為下列三說：

1. 二分肢說

（Die zweigliedrige Theorie od. Streitgegenstandslehre）

採二分肢說之學者（主要是Leo Rosenberg於1927⁴⁹）認為訴訟標的乃是訴訟上之請求權而與實體法之權利（請求權）無涉。目前

⁴⁵ Vgl. Jauernig/Hess (Fn. 1), § 37 III.

⁴⁶ Wolfram Henckel, Stein/Jonas – ein Großkommentar zur Zivilprozeßordnung, JZ 1992, S. 645 (648).

⁴⁷ Vgl. Detterbeck (Fn. 34), S. 43 f.

⁴⁸ Vgl. Seiler (Fn. 40), Einl. II Rn. 11.

⁴⁹ Nikisch亦屬主要支持者，但其後改採新實體法說。參見陳榮宗，民事程序法與訴訟標的理論，再版，頁337、344（1984年）。

多數德國學者認為二分肢說⁵⁰乃是確定訴訟標的概念之適當標準，德國聯邦最高法院亦有許多判決傾向此說⁵¹。依據二分肢說，訴訟標的係由訴之聲明（原告之權利主張或請求）和作為請求基礎之原因（生活事實 *Lebenssachverhalt*）所構成。訴之聲明縱使相同，若生活事實不同，訴訟標的仍非相同。因此，訴之聲明縱使單一，若生活事實多數，訴訟標的即為多數。若訴之聲明為多數，縱使生活事實相同，訴訟標的亦為多數⁵²。許多學者認為權利保護之形式（*Rechtsschutzform*）屬於訴訟標的之一部分⁵³，蓋請求權利保護之形式係直接透過訴之聲明⁵⁴之方式顯現，又，訴之聲明常被以法律效果之主張（*Rechtsfolgenbehauptung*）⁵⁵或請求（*Begehren*）表示，但此種用語區別並無實質上之差異⁵⁶。所謂之生活事實係指引起訴訟之生活事件，乃是原告之請求和聲明之基礎，又稱為訴之原因訴因（*Klagegrund*）或請求之原因（*Anspruchsgrund*）。生活事實係由個別事實（*Tatsachen*）組成。二分肢說和一分肢說相同，皆須以生活事實確定訴訟標的，縱使生活事實之概念有時並非明確，亦無法棄而不用⁵⁷。

⁵⁰ Vgl. *Jauernig/Hess* (Fn. 1), § 37 IV, VI.

⁵¹ Z.B. *Leo Rosenberg/Karl Heinz Schwab/Peter Gottwald*, *Zivilprozeßrecht*, 15. Aufl., 1993, § 95 III 2; *Hans-Joachim Musielak*, *Grundkurs ZPO*, 1991, Rn. 129; *Habscheid* (Fn. 44), S. 182; *Seiler* (Fn. 40), Einl. II Rn. 24 ff.; *Gerhard Lüke*, *Münchener Kommentar ZPO*, 2. Aufl., 2002, vor § 253 Rn. 33; BGHZ 94, 29 (34); 79, 245 (248 f.); 78, 130 (136); NJW 1981, S. 2306; 1983, S. 389; 1990, S. 1716; 1990, S. 1796.

⁵² Vgl. *Detterbeck* (Fn. 34), S. 39.

⁵³ Vgl. *Detterbeck* (Fn. 34), S. 40; *Seiler* (Fn. 40), Einl. II Rn. 15; *Gerhard Lüke*, *Münchener Kommentar ZPO*, vor § 264 Rn. 3, 14, 18.

⁵⁴ 不同權利保護形式之訴之聲明通常即為不同訴訟種類，例如給付訴訟和確認訴訟。

⁵⁵ *Richard Zöller*, *Zivilprozeßordnung*, 18. Aufl., 1993, Einl. Rn. 63; *Ekkehard Schumann*, in: *Stein/Jonas* (Hrsg.), *Kommentar zur ZPO*, Bd. 1, 20. Aufl., 1984, Einl. Rn. 270.

⁵⁶ Vgl. *Habscheid* (Fn. 44), S. 183; *Detterbeck* (Fn. 34), S. 41.

⁵⁷ Vgl. *Detterbeck* (Fn. 34), S. 70 ff.

行政訴訟對於生活事實之概念，係以行政行為（行政處分）規範之生活事實為範圍，因此較民事訴訟之概念明確而較少爭議⁵⁸，且由於行政法院應依職權調查事實，因此生活事實之範圍亦較民事訴訟易於確定⁵⁹。基於處分權主義，以何種生活事實作為訴訟標的，係由原告確定，法院之職權調查義務僅在原告指定之生活事實範圍內為之。惟原告僅須大概指出其訴訟涉及何事件，不須精確描述。對於牽涉整個生活事件之個別事實進行說明，則屬原告之協力義務⁶⁰。生活事件之範圍應客觀認定，故原告確定生活事實（例如原告被控擾亂公共秩序而被罰鍰之事件）之後，無權圈定該生活事件之範圍，更無權指定哪一個組成生活事實之個別事實（例如違法燃放鞭炮、大聲喧嘩、叫囂、騷擾他人等）應作為裁判之基礎，法院應基於哪些個別事實裁判，係由法院自行決定⁶¹。此外，有些主張本說之人認為，並無任何實體法之請求權授與權利人得向法院為請求（裁判）之權利，因此不能將訴訟標的解為實體法上之權利⁶²。

在撤銷訴訟，多數德國學者依Christian-Friedrich Menger之見解，認為依行政法院法第42條第2項及第113條第1項第1句之用語⁶³，撤銷訴訟之訴訟標的應是原告指摘行政處分違法並侵害其權

58 Vgl. BVerwGE 60, 123 (125); 29, 1 (2); NVwZ 1994, S. 1115; Jura 1990, S. 45; NJW 1984, S. 1578; NVwZ 1991, S. 258; Günther Barbey, Bemerkungen zum Streitgegenstand im Verwaltungsprozeß, in: Hans-Uwe (Hrsg.), System des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes: Festschrift für Christian-Friedrich Menger zum 70. Geburtstag, 1985, S. 177 (182); Detterbeck (Fn. 34), S. 52 ff.

59 Vgl. Detterbeck (Fn. 34), S. 72.

60 Vgl. Detterbeck (Fn. 34), S. 77.

61 Vgl. Detterbeck (Fn. 34), S. 79 ff.

62 Vgl. Detterbeck (Fn. 34), S. 64.

63 Vgl. Peter Lerche, Zum Stand der Lehre vom Streitgegenstand im Verwaltungsprozeß, BayVBl 1956, S. 295 (297); 行政法院法第42條第2項規定：「除法律別有規定外，僅於原告主張其因該行政處分或拒為處分或不作為而侵害權利時，其訴始為合法」（Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, ist die Klage nur zulässig, wenn der Kläger geltend macht, durch den Verwaltungsakt oder

益之主張⁶⁴，故依此說，撤銷訴訟之訴訟標的係由行政處分之違法性以及侵害原告之權益兩部分組成。而違法性之判斷即以行政處分規制之社會生活事實為基礎，若生活事實不同，訴訟標的即屬有異。我國行政法學者對於行政訴訟訴訟標的之定義，大多如同德國之多數說而傾向二分肢說，認為訴訟標的按訴訟種類之不同，原告所為訴訟上之權利主張，而所謂撤銷訴訟之訴訟標的，係指原告認為行政處分違法並侵害其權益之主張，而非系爭之行政處分⁶⁵。更有學者認為，撤銷訴訟之訴訟標的，應包括原告要求確認該行政處分違法並侵害其權利，以及廢棄該行政處分之訴訟上請求⁶⁶。

雖然法院之判決多數趨向二分肢說，然而有認為法院其實僅在解決和訴訟標的相關之個別問題，並未對於訴訟標的的做出一般性之定義，因此，聯邦最高法院是否確定採用二分肢說，仍有待繼續觀察⁶⁷。

2. 一分肢說

（Die eingliedrige Theorie od. Streitgegenstandslehre）

主張一分肢說者（主要是Karl Heinz Schwab於1954）認為，訴訟標的完全由原告之訴之聲明構成，支持訴之聲明之實體請求權僅

seine Ablehnung oder Unterlassung in seinen Rechten verletzt zu sein.)；第113條第1項第1句規定：「若行政處分違法並侵害原告之權利，法院應將該處分及相關訴願決定撤銷。」（Soweit der Verwaltungsakt rechtswidrig und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt ist, hebt das Gericht den Verwaltungsakt und den etwaigen Widerspruchsbescheid auf.）

⁶⁴ Vgl. Ule (Fn. 12), § 35 II 3; Grunsky (Fn. 41), § 5 IV, S. 42; Detterbeck (Fn. 34), S. 154.

⁶⁵ 「就撤銷訴訟而言，其標的係指原告對行政處分違法並損害權利之主張（參見本法第4條）——不可將系爭之行政處分誤為訴訟標的」，參見吳庚，行政法之理論與實用，增訂13版，頁685（2015年）；蔡志方，行政救濟法新論，頁224（2001年）。

⁶⁶ 陳敏（註21），頁1471。

⁶⁷ Vgl. Detterbeck (Fn. 34), S. 24 f.

屬法律觀點，非裁判之對象，法院應將所有可能支持訴之聲明之法律觀點（實體法之請求權基礎）進行審查。由於訴之聲明構成訴訟標的，若聲明不同，訴訟標的即不相同，故請求保護之方式不同，例如請求確認或請求給付，即屬於不同之訴訟標的⁶⁸。本說之判斷標準並非明確，在給付訴訟，若訴之聲明涉及金錢或不特定物之給付，須和特定生活事實（*Lebenssachverhalt*）相結合，始能特定訴訟標的。但採一分肢說之學者認為特定之生活事實僅是用於確定訴訟標的，生活事實本身並非訴訟標的之構成部分。因此，縱使不同之原因事實，若聲明為單一，訴訟標的僅為一個，反之，若訴之聲明多數，縱使皆源於同一事實，訴訟標的亦為複數⁶⁹。

3. 三分肢說

（Die dreigliedrige Theorie od. Streitgegenstandslehre）

於德國和奧地利民事訴訟法文獻有（主要是Peter Böhm）提出三分肢說，認為訴訟標的係由權利保護之目的（*Rechtsschutzziel*，相當於權利之主張或訴之聲明）和原因事實共同構成，但權利保護目的和原因事實仍須藉助於裁判應適用之實體法規而確定，是以此等法規亦屬於訴訟標的之構成要素⁷⁰。三分肢說主張，除訴訟上之權利保護目的（訴之聲明）和生活事實之外，應加入實體法之權利保護請求（或稱之為實體之權利保護目的（*materielle Rechtsschutzziel*）），即個案中應適用之實體法規，經由此項實體法規而確定、限制所謂之生活事實之範圍。依據此說，判斷兩訴訟案件是否同一應依下列三要素決定之：1. 前訴判決對象之法律效果和後訴判決對象之法律效果相同（被包含、相反或可代用），2. 兩訴訟涉及相同之生活事實，3. 前後兩訴適用之實體法規（請求權規範）屬於

⁶⁸ Vgl. *Detterbeck* (Fn. 34), S. 34 f.

⁶⁹ Vgl. *Detterbeck* (Fn. 34), S. 34.

⁷⁰ Vgl. *Habscheid* (Fn. 44), S. 194.

同一類別 (Kategorie)。所謂「同一類別」係指作用上同值，意義上同一 (funktionelle Gleichwertigkeit, Sinneinheit) 而言⁷¹。有學者將三分肢說歸諸於Walther J. Habscheid之主張⁷²，因其認為訴訟標的乃是「原告之權利主張，請求在其選取之程序中，判決給予其基於特定生活事實而生之法律效果」，此外，其認為原告之請求不但針對法院，並針對被告⁷³。雖然有學者認為Habscheid之三要素（程序主張、權利主張和事實）與實體法並無關連，因此不屬於此之三分肢說⁷⁴，惟拙見認為，縱使Habscheid並非主張三分肢說，惟其見解確實和三分肢說相近，例如其認為，「權利之請求（或權利主張）已表明，訴訟標的之概念和具體之請求權並非同一，或換言之，在訴訟中並非僅有實體法之請求權被起訴請求，而且亦包括權利確認之請求或實行形成訴訟之權利。⁷⁵」（粗體字為本文所強調）

據此可知，Habscheid認為訴訟標的和實體權利關係密切，職

71 Vgl. Peter Böhm, Die Ausrichtung des Streitgegenstandes am Rechtsschutzziel, in: Rechberger/Welser (Hrsg.), Festschrift für Winfried Kralik zum 65. Geburtstag: Verfahrensrecht – Privatrecht, 1986, S. 83 (109 ff.); Detterbeck (Fn. 34), S. 42.

72 Vgl. Diter Hesselberger, Die Lehre vom Streitgegenstand, 1970, S. 196 ff. 轉引自 Detterbeck (Fn. 34), S. 40.

73 Walther Jakob Habscheid, Der Streitgegenstand im Zivilprozeß, 1956, S. 221 f.: „die Rechtsbehauptung des Klägers, ihm sei in dem eingeschlagenen Verfahren die begehrte Rechtsfolge aufgrund eines bestimmten Lebenssachverhalts zuzusprechen.“

轉引自 Detterbeck (Fn. 34), S. 40; Habscheid (Fn. 44), S. 183。Detterbeck認為Habscheid並非如此主張，其認為Habscheid之權利主張不但包括法律效果之主張，更包括程序主張，亦即在其所選取之程序中判決給予宣告。因此Habscheid為二分肢說之主張者。

74 Vgl. Detterbeck (Fn. 34), S. 43.

75 Habscheid (Fn. 44), S. 183: „Rechtsbegehren (oder Rechtsbehauptung) ist klargestellt, daß der Streitgegenstandsbegriff nicht identisch ist mit dem konkreten Anspruch, oder weiter formuliert: Im Prozeß werden nicht nur Ansprüche i. S. des materiellen Rechts eingeklagt, sondern es wird auch Rechtsfeststellung begehrt oder ein Gestaltungs-klagerecht durchgesetzt.“

是之故，陳榮宗教授認為Habscheid之主張應屬於三分肢說⁷⁶。

(五) 訴訟上之行政處分撤銷請求權

某些德國學者和德國聯邦行政法院之判決認為，撤銷訴訟之訴訟標的乃是原告請求撤銷行政處分之訴訟上請求權⁷⁷。例如Detterbeck認為，行政法院法第42條第2項和第113條第1項第1句並不足以支持行政處分之違法以及侵害原告權益成為訴訟標的之論點，蓋條文之用語並未對訴訟標的作出定義，雖然上揭條文皆以行政處分違法且侵害原告權益為要件，然而此兩者亦可能為原告勝訴判決之理由（勝訴判決之要件），並無必認其為訴訟標的之充分依據。此外，因為訴訟標的並非行政處分，故第113條第1項第1句之規定不可能針對訴訟標的。假如認為判決（主文）之內容出於訴訟標的之內容，則撤銷訴訟之勝訴判決內容乃是撤銷違法之行政處分，因而訴訟標的之內容即應為原告訴訟上之撤銷請求權（*Aufhebungsanspruch des Klägers*）。行政處分之撤銷乃是訴訟標的的經裁判後之法律效果，而處分違法及侵害原告權益乃是其先決要件。更進一步言，原告提起撤銷訴訟之目的並非在於確認行政處分之違法性以及侵害其權利，而是請求將該處分撤銷，因此不應將訴訟標的解為係行政處分之違法性以及侵害原告之權利兩者，而應認為是撤銷行政處分之訴訟上請求權。據此，法院之撤銷判決對於行政處分之違法性以及侵害原告權利之認定並不生確定效力⁷⁸。Detterbeck認為原告提起撤銷訴訟所欲排除者乃是行政處分規範之權利義務，若原處分機關在判決確定後，於原因事實不變之情形下，對先前之原告又作出內容和原處分完全相同之新處分時，由於訴訟標的的經判決後之實質確定效力，於原告再起訴後，法院不須重

76 參見陳榮宗（註49），頁339、340。依陳榮宗之見解，Habscheid認為訴訟標的係由程序主張、權利主張及生活事實三者共同構成。

77 BVerwGE 60, 123 (125); 29, 1 (2); NVwZ 1994, S. 1115; Schenke (Fn. 2), § 90 Rn. 7.

78 Vgl. Detterbeck (Fn. 34), S. 154 ff.

為實質審理，即可將之撤銷，由此可知，撤銷訴訟之勝訴判決亦含有某程度之預防作用，亦即行政機關於判決確定後不得對於同一事實（事件）作出內容相同之行政處分，若依原告之訴訟上撤銷請求權說之見解，即無此弊端⁷⁹。

（六）相對之訴訟標的說

德國文獻上亦有主張訴訟標的應隨不同訴訟狀況而異，亦即得隨時調整、變更。本說之基本概念在於區別訴訟標的（訴訟進行中）和判決標的（Urteilsgegenstand訴訟終結時），不同訴訟種類之訴訟標的亦應不同⁸⁰。亦有主張若適用職權調查主義之訴訟，應將訴訟標的之概念擴大解釋，若適用當事人提出主義（辯論主義）之訴訟，則將訴訟標的之概念縮小解釋⁸¹。目前於我國行政（訴訟）法文獻上似無採取此種見解者。

三、小結

德國學者幾乎皆同意藉由民事訴訟之訴訟標的理論來解釋行政訴訟訴訟標的之概念，且大多數之學者認為訴訟標的係訴訟法之概念，因此拒絕將實體法之請求權作為訴訟標的，因而採純粹（舊）實體法說者甚少⁸²，雖然如此，許多學者實質上卻將其他實體法之要素列入訴訟標的之概念，特別是在撤銷訴訟，由於多數說認為，撤銷訴訟之訴訟標的係行政處分之違法性以及侵害原告之權益，又因為違法性之審查和是否因而侵害原告權益原則上須依實體法作為判斷基準，是以撤銷訴訟之訴訟標的即涉及實體法之規定，職是之故，亦有認為撤銷訴訟之訴訟標的並非以訴訟法說，而是以實體法

⁷⁹ Vgl. *Detterbeck* (Fn. 34), S. 158 ff.

⁸⁰ Vgl. *Schumann* (Fn. 55), Einl. Rn. 283 ff.

⁸¹ *Othmar Jauernig*, Verhandlungsmaxime, Inquisitionsmaxime und Streitgegenstand, 1967; *Othmar Jauernig*, Zivilprozessrecht, 25. Aufl., 1998, § 37 VIII.

⁸² Vgl. *Detterbeck* (Fn. 34), S. 25, 50.

說作為主要之判斷標準⁸³。在課以義務訴訟，聯邦最高行政法院亦曾於判決中表示，課以義務訴訟之訴訟標的應包含事實和法律問題之判斷基準時，由於基準時之判斷需依據實體法，因此訴訟標的之認定受到實體法準則之限制⁸⁴。

多數德國學者強烈反對實體法說之理由如下：首先，同一行政處分侵害數（人之）權利時，被認為僅有單一訴訟標的存在，此外，原告主張侵害其權益，並非限定特定之實體權利，而是指其所有之權利整體（權利單一性）而言，故只要確實侵害其權利，即符合法律要求，因此行政法院判決之確定效力並不針對原告之特定權利。因而，雖原告提出行政處分違法並侵害其權利之主張，屬於訴訟標的之構成部分，仍與實體法說之主張不同。其次，是否違法，係依整體法規範判斷，而非基於原告所指之具體法規，因而縱使將行政處分之違法性作為訴訟標的之構成要素，與實體法說仍無直接關連。其三，違法基準時之判斷應屬於判決之理由而非訴訟之標的，且基準時之判斷並非一致，應依個案決定，若將之列為訴訟標的，將使訴訟標的之認定陷於不明確⁸⁵。雖然撤銷訴訟之訴訟標的確實和實體法具有相當關連，然而仍不能將之列為訴訟標的之要素。但亦有學者認為撤銷訴訟之權利侵害主張係基於相同生活事實時，始能將實體權利視為整體，而認為其訴訟標的同一，若係基於不同生活事實，即不能將權利整體觀察（權利單一性）⁸⁶。

屬於訴訟法說之三分肢說遭到絕大多數學者排斥，蓋其認為三分肢說同時將實體法與訴訟法涵蓋於訴訟標的之概念下，體系矛

83 Vgl. *Lerche* (Fn. 63), S. 297; *Grunsky* (Fn. 41), S. 42: „Zur Beurteilung der h. M. ist es nützlich, sich vor Augen zu halten, daß für den Bürger mit Erlaß des rechtswidrigen Verwaltungsaktes ein materiellrechtlicher Anspruch auf Aufhebung des Verwaltungsaktes entsteht.“

84 Vgl. BVerwG, DVBl. 1992, S. 1224; JZ 1992, S. 1078.

85 Vgl. *Detterbeck* (Fn. 34), S. 51 f.

86 Vgl. *Detterbeck* (Fn. 34), S. 54 f.

盾，且其理論內容散亂，何種實體請求權屬於作用上、意義上相同價值，為同一領域，亦無法明白說明⁸⁷。而行政處分說未將程序（攻擊）標的和訴訟標的區分，且原告對於該行政處分之存在及其內容並未爭執，此外，依此見解將使違法性和侵害權益之主張變成先決問題，此有違德國行政法院法第113條（我國行政訴訟法第4條第1項）之規定，故目前幾乎無人採行政處分作為訴訟標的之見解⁸⁸。惟德國多數學者亦不採訴訟上撤銷請求權說，蓋依該說之見解，則違法性之認定僅係撤銷行政處分之先決要件，並無確定力，無法拘束其後提起之國家賠償訴訟，因而法院於國家賠償訴訟不受之前撤銷訴訟原告勝訴判決之拘束，可能作出與前判決歧異之認定，是以此說忽視行政處分之違法性認定屬於撤銷訴訟之重心，行政處分之撤銷乃是行政處分違法邏輯上之當然結果⁸⁹。此外，若採此說，因事實認定及法規適用並非訴訟標的，不生實質確定力，則原處分機關得於同一原因事實下適用相同法規重複做出與之前被撤銷之處分內容相同之新處分而不違背前判決之確定力，蓋對新處分不服時，相對人仍有相對應之撤銷請求權，換言之，撤銷請求權係針對個別之行政處分而生，不論其內容是否相同，此將產生與行政處分說之同樣弊端，人民因尋求救濟而疲於奔命，若不及時提起救濟則將受新處分拘束，對其權益保障勢必產生極大之侵害。又，絕大多數德國學者認為，訴訟標的於起訴時即應抽象一致確定，相對訴訟標的理論無法提出抽象一致之適用標準，導致訴訟標的之內涵須依個別案件且個別訴訟程序進行階段判斷，一切取決於個別情

87 Vgl. *Habscheid* (Fn. 44), S. 195; *Detterbeck* (Fn. 34), S. 46.

88 Vgl. *Lerche* (Fn. 63), S. 296; *Detterbeck* (Fn. 34), S. 61 f.

89 Vgl. *Grunsky* (Fn. 41), § 5 IV, S. 43; *Lerche* (Fn. 63), S. 298; *Klaus Rennert*, in: *Eyermann/Fröhler* (Hrsg.), *Verwaltungsgerichtsordnung*, 11. Aufl., 2000, § 121 Rn. 12; *Konrad Redeker*, Anmerkung zum Urteil des BVerwG vom 24.01.1992 – 7 C 24.91, DVBl 1992, S. 1225 (1225); *Jörn Schroeder-Printzen*, Die Beschwer des beigeladenen Sozialleistungsträgers über §§ 102 ff. SGB X - Zugleich ein Beitrag zu Problemen der Beiladung, NVwZ 1990, S. 614 (617); *Detterbeck* (Fn. 34), S. 160 f.

況，終將導致紛亂而難以適用，特別是關於是否重複起訴、訴之變更、追加、合併等問題，皆須依抽象一致之訴訟標的概念解決，相對訴訟標的理論難以提供明確公平之方案⁹⁰。

訴訟標的確屬訴訟法之概念，其主要之作用在於確定審判之對象、範圍以及判決之確定力，而應依訴訟法之觀點解釋，然而訴訟之目的主要是在於貫徹、維護實體法之權利及法秩序，職是之故，脫離實體法則訴訟即無意義，絕大多數學者皆承認，訴訟標的之概念不能和實體法分離，尤其是確認訴訟，其主要係以實體法之法律關係為確認對象，更離不開實體法⁹¹。形成訴訟係原告請求法院以判決直接創設、變更或消滅實體法律關係，撤銷訴訟既屬於形成訴訟之一種類型，亦不能排除此性質。將訴訟標的認為係訴訟法之概念並非意味亦應將實體法之要素全然排除於訴訟標的之概念外，甚至主張新實體法說之學者亦不反對將訴訟標的歸類為訴訟法之概念⁹²，故完全排除實體法之要素以詮釋訴訟標的是否妥適、周延，應有商榷之處。原告起訴主張訴訟上之裁判請求權，原則上即同時在行使（主張）其實體法之權利，何況當事人所爭執者係實體法之權利義務關係，而且訴訟標的之內容亦和原告請求之權利保護方式有關，雖說從訴訟程序上觀察，原告起訴係請求法院作出判決，惟從實體上觀察，原告之訴係針對被告，法院若未針對原、被告就兩造爭執之實體權利義務關係為裁判，即不符原告起訴之目的，此外，判決之確定效力亦包含主觀之拘束力，是以訴訟標的之判斷亦包含人之要素，若當事人（被告）變更，原則上訴（訴訟標的）即

90 Vgl. *Peter Gottwald*, in: *Krüger/Rauscher* (Hrsg.), *Münchener Kommentar ZPO*, Bd. 1, 2. Aufl., 2000, § 322 Rn. 106; *Musielak* (Fn. 51), Rn. 126; *Henckel* (Fn. 46), S. 645, 647 f.; *Barbey* (Fn. 58), S. 178 f.; *Detterbeck* (Fn. 34), S. 45.

91 Vgl. *Grunsky* (Fn. 41), § 5 IV, S. 40; *Habscheid* (Fn. 44), S. 181 f., 188; *Lerche* (Fn. 63), S. 298; *Schenke* (Fn. 2), § 90 Rn. 11; *Detterbeck* (Fn. 34), S. 54 ff. 然而 *Detterbeck* 卻排斥將實體法之要素列入訴訟標的之概念而採純粹訴訟法說，其認為訴訟標的乃是訴訟法之請求權。

92 Vgl. *Detterbeck* (Fn. 34), S. 55.

發生變更⁹³，職是之故，單從原告和法院之訴訟法上關係來界定訴訟標的之概念，而忽略實體法之因素，顯有失之偏狹之誤。周延之道，勢必應從原告對於法院及被告之觀點（三面關係）出發，將實體法之要素亦列入考慮，而界定訴訟標的之概念，庶幾能得確論⁹⁴。

三分肢說最受人非難之部分，係其主張判斷前後案件是否為同一訴訟標的，應考慮前後兩訴適用之實體法規（請求權規範）是否屬於同一類別，而所謂「同一類別」，則用抽象含混之作用上同值、意義上同一說明。然而拙見認為，該缺陷係因主張者採請求權規範競合說而生，若將裁判應適用之實體法規依請求權競合說認定，不同之實體法請求權皆各自獨立而為不同訴訟標的，該說即可明確、簡便被適用。此外，拙見認為，若依原告之聲明及事實上之陳述，得主張數項法律關係，而其主張不明瞭或不完足者，審判長應曉諭其敘明或補充之（民事訴訟法第199條之1參照）。若能配合律師之代理，則原告藉由律師之協助，於同一訴訟將所有可能適用之實體法規（主張之實體權利）全部提出，應可有效避免原告因同一目的而得提起多次訴訟之缺陷。

若依我國行政訴訟法之用語，似應以行政處分說⁹⁵或舊實體法說⁹⁶作為確定撤銷訴訟訴訟標的之準則，然而若考慮訴訟標的係屬於訴訟法之概念，應包含當事人訴訟上對於法院之判決請求，再參酌行政訴訟（撤銷訴訟）之起訴之要件（違法及侵害權益之主張）

93 例如依我國之通說認為，確認某物之所有權屬於甲和確認該物之所有權屬於乙係不同之訴訟標的。惟德國民事訴訟之通說認為當事人之變更並非訴之變更。

94 Vgl. Detterbeck (Fn. 34), S. 64 ff.

95 行政訴訟法第37條第1項第1款：「為訴訟標的之行政處分係二以上之機關共同為之者，……」、第197條規定：「撤銷訴訟，其訴訟標的之行政處分涉及金錢或其他代替物者，……」。

96 例如行政訴訟法第110條第1項：「訴訟繫屬中，為訴訟標的之法律關係雖移轉於第三人，於訴訟無影響。但第三人如經兩造同意，得代當事人承當訴訟。」

及原告之缺乏法律專業知識，要求其指出案件涉及之具體實體法權利或法律關係誠屬強人所難，令其指出並確定案件所針對之生活事實，使法院得以確定於該案件判決應適用之實體法規即已足夠，由於訴之聲明係原告起訴追求之目的，為整個訴訟之核心，而生活事實在訴訟上係適用法律之基礎，亦係訴之聲明之依據，為攻擊防禦、證據調查甚至整個言詞辯論之主要部分，而在給付訴訟或形成訴訟，亦常藉由生活事實始能確定訴訟標的。判決所適用之實體法規係生活事實之法律評價，為確定訴之聲明有無理由之依據，其實現即為當事人（原告）進行訴訟之目的，若略之不顧，訴訟即無所附麗而失其意義⁹⁷，其對於訴訟標的之確定亦具有相當之作用。據此，訴訟標的之內涵應包括三要素，亦即訴訟上之權利保護請求（訴之聲明）、生活事實以及實體法之權利保護請求（訴訟個案中應適用之實體法規）皆應屬於訴訟標的之構成要素。我國文獻亦有認為縱使依舊實體法說判斷給付訴訟之訴訟標的，仍應就原告之訴之聲明及起訴之原因事實一併判斷者，例如黃茂榮教授認為：「其結果，舊訴訟標的理論據以特定訴訟標的之要素為：原因事實、請求權及訴之聲明。⁹⁸」而陳榮宗、林慶苗之著作認為：「簡言之，給付訴訟之訴訟標的，在實務上特定方法係，將訴之聲明及起訴之原因事實兩者一併為具體之判斷，並將原告所主張之實體法律關係及其給付請求權作為識別訴訟標的之特定方法。」此外，其認為在確認訴訟，特定訴訟標的之方法，亦必須同時就以訴之聲明及起訴之事實理由為具體表明及主張始可。據此應可得知其主張與三分肢說相當近似⁹⁹。

97 例如陳敏認為：「僅以行政處分之廢棄請求為訴訟標的，而不及於實質之法律關係，則無法拘束行政機關在事實狀況未改變時，以相同之理由重為被撤銷之行政處分。」參見陳敏（註21），頁1471。

98 參見黃茂榮，論訴訟標的，植根雜誌，20卷1期，頁5（2004年）。

99 參見陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（上冊），修訂6版，頁298-299（2009年）。然而其認為於確認訴訟，事實和法律解釋並非訴訟標的。

在德國文獻上亦有類似之見解，認為有別於其他訴訟之稅務訴訟之訴訟標的，其特殊性在於以權利保護之請求（Rechtsschutzbegehren）所主張之法律（權利）地位必須被歸入實體法之稅法關係，並標示出由許多法律上之個別判定（Einzelentscheidungen）結合成之多層次事實組合（整體事實 Sachverhaltskomplex），且審酌與此相應之許多法規範¹⁰⁰。

最高法院100年度台抗字第62號民事判決亦認為：

按民國89年2月9日修正之民事訴訟法第244條第1項第2款，將原規定之「訴訟標的」修正為「訴訟標的及其原因事實」，乃因訴訟標的之涵義，必須與原因事實相結合，以使訴狀所表明請求法院審判之範圍更加明確。則於判斷既判力之客觀範圍時，自應依原告起訴主張之原因事實所特定之訴訟標的法律關係為據，凡屬確定判決同一原因事實所涵攝之法律關係，均應受其既判力之拘束，且不得以該確定判決言詞辯論終結前，所提出或得提出而未提出之其他攻擊防禦方法，為與該確定判決意旨相反之主張，此乃法院應以「既判事項為基礎處理新訴」及「禁止矛盾」之既判力積極的作用，以杜當事人就法院據以為判斷訴訟標的權利或法律關係存否之基礎資料，再次要求法院另行確定或重新評價，俾免該既判力因而失其意義，亦即既判力之「遮斷效」。（粗體字為本文所強調）

此判決亦認為應以實體法規特定生活事實，藉以確定訴訟標的，其見解實質上似乎趨向三分肢說。

¹⁰⁰ Vgl. Fritz Gräber, in: Groll/Koch/Ruban/Stapperfend (Hrsg.), Finanzgerichtsordnung, 6. Aufl., 2006, § 65 Rn. 39.

肆、訴訟和解之效力

一、關於訴訟程序之效力

訴訟和解在訴訟上之主要作用係具有終結訴訟繫屬之效力，若法院之前曾作出終局判決，該判決將因當事人締結和解而失效¹⁰¹。由於和解之二元性質，故訴訟和解之生效亦須以實體法之和解有效為前提，實體法無效之和解，亦不成立訴訟和解，因此，在訴訟和解，當事人亦須遵守行政程序法關於和解契約之規定，始能有效成立訴訟和解。若和解違反實體法之規定無效，而當事人仍合意願終結訴訟，則依個案或可認為當事人成立獨立之訴訟契約，由原告負撤回起訴之義務¹⁰²。違背訴訟法之強制規定，但不違背實體法之強制規定者，雖不成立訴訟和解，仍可成立實體法之和解¹⁰³，但訴訟繫屬不因之終結。惟實體法律爭議已解決後，原告仍不撤回起訴時，依多數見解，應認為原告之訴欠缺權利保護必要，其訴因欠缺實體判決之要件而不合法，由法院以裁定駁回之¹⁰⁴。此外，當事人於訴訟和解時，亦得同時就訴訟費用之部分成立和解¹⁰⁵。

二、「準確定判決」之效力

從比較法上觀察，依德國民事訴訟法第794條第1項第1款、行政法院法第168條第1項第3款之規定（§ 794 I Nr. 1 ZPO; § 168 Abs. 1 Nr. 3 VwGO）以及實務、通說之見解，訴訟和解並無與確定判決相同之確定力，僅於和解內容適於執行時，得作為執行名義¹⁰⁶，因

¹⁰¹ Vgl. Jauernig/Hess (Fn. 1), § 48 V; Seiler (Fn. 40), § 794 Rn. 26, 28.

¹⁰² Vgl. Eyermann/Geiger (Fn. 11), § 106 Rn. 25.

¹⁰³ Vgl. Eyermann/Geiger (Fn. 11), § 106 Rn. 6.

¹⁰⁴ Vgl. Eyermann/Geiger (Fn. 11), § 106 Rn. 26, 27.

¹⁰⁵ Vgl. Eyermann/Geiger (Fn. 11), § 106 Rn. 28.

¹⁰⁶ Vgl. Jauernig/Hess (Fn. 1), § 48 V; Kothe (Fn. 15), § 106 Rn. 12; Eyermann/Geiger (Fn. 11), § 106 Rn. 6; Schenke (Fn. 2), § 106 Rn. 23.

此，除終結訴訟（繫屬）及得為執行名義之效力外，原則上並無其他訴訟法之效力¹⁰⁷。本法第222條之規定：「和解成立者，其效力準用第213條、第214條及第216條之規定。」然而，訴訟和解畢竟與確定判決性質有異，是以，訴訟和解之效力究應如何準用第213條、第214條及第216條之規定，不無疑義，而且，由於行政訴訟法關於和解效力之規定與民事訴訟法有關和解效力之規定用語有異¹⁰⁸，其效力是否相同，亦有疑義，茲探討如下。

（一）訴訟和解之積極和消極效力和本法第215條排除準用之效果

訴訟和解之實體效力包含積極效力和消極效力兩種，前者係指當事人之間依和解契約發生新法律關係並取代原有之法律關係，亦即和解契約締結後，在當事人之間僅存新發生之法律關係，舊有之法律關係對當事人而言原則上已不存在；後者係指當事人於和解契約生效後不得主張和解前之原有狀態¹⁰⁹。如前所述，由於訴訟和解屬於契約，故訴訟和解之實體法效力僅及於和解之當事人間，除非第三人加入和解或同意，否則效力不及於第三人。和解之主觀效力亦及於訴訟繫屬後為當事人之繼受人者，以及為當事人或其繼受人佔有請求標的物之人。

此外，由於訴訟和解同時具有實體法和解之性質，而該實體契約應屬於債權契約性質，因此，若訴訟標的涉及之實體權利屬於絕對權（對世權），例如身分權或物之所有權等時，當事人縱使和解，該和解之效力不得發生與確定判決相同之對世效力¹¹⁰，因其屬

107 Vgl. Barbara Völzmann-Stickelbrock, in: Prütting/Gehrlein (Hrsg.), ZPO, 3. Aufl., 2011, § 322 Rn. 13. 由於訴訟和解具有執行力係規定於行政法院法，且德國之強制執行亦規定於民事訴訟法中，是以具有執行名義之效力應可認為屬於訴訟法之效力。

108 民事訴訟法第380條第1項規定：「和解成立者，與確定判決有同一之效力。」

109 Vgl. Bonk (Fn. 24), § 55 Rn. 52.

110 最高法院61年台再字第186號民事判例參照。

於（債權）契約，僅對契約雙方生效，對未參與和解之第三人不生拘束力。職是之故，本法第222條之準用規定並不包括第215條，蓋該條規定：「撤銷或變更原處分或決定之判決，對第三人亦有效力。」，係具有對世效力之性質，使債權契約之和解具有對世效力顯然不符其本質，況且，訴訟和解乃當事人之契約，並非法院之判決，因此，其亦不應具有司法高權特有之效力，依實務向來之見解，皆認為於形成訴訟，當事人若成立和解，僅屬實體法之和解，不能認為具有訴訟和解之性質，因而否定於形成訴訟得成立訴訟和解。例如最高法院58年台上字第1502號民事判例認為：

調解成立者，依民事訴訟法第416條第1項，第380條第1項規定，與確定判決有同一之效力。惟判決為法院對於訴訟事件所為之公法的意思表示，調解或和解，為當事人就訴訟上之爭執互相讓步而成立之合意，其本質並非相同。故形成判決所生之形成力，無由當事人以調解或和解之方式代之，從而在調解或訴訟上和解分割共有不動產者，僅生協議分割之效力，非經辦妥分割登記，不生喪失共有權，及取得單獨所有權之效力。（粗體字為本文所強調）

最高行政法院96年度判字第1606號判決亦認為：

本院按：「和解成立者，與確定判決，有同一之效力。」、「確定判決，除當事人外，對於訴訟繫屬後為當事人之繼受人者，……亦有效力。」民事訴訟法第380條第1項、第401條固分別定有明文。惟判決為法院對於訴訟事件所為公的意思表示，調解或和解為當事人就訴訟上之爭執互相讓步而成立之合意，其本質並非相同，故形成判決所生之形成力，無由當事人以調解或和解之方式代之。從而，在調解或訴訟上和解分割共有不動產者，僅生協議分割之效力，非經辦妥分割登記，不生喪失共有權及取得單

獨所有權之效力，最高法院58年台上字第1502號判例足參。再「於分割共有物事件中，當事人於訴訟繫屬後將土地共有權移轉於受讓之第三人，無論其移轉係於該訴訟事件訴訟上之和解前或和解後，所謂其和解之效力均及於受移轉之第三人，係指受讓人其受讓之權利範圍，僅局限於該讓與之當事人所分得之部分，至當事人若並非將其應有部分全部移轉於第三人，其與受讓之第三人如何定其共有關係之登記，則非原訴訟上和解效力所及之範圍」，此亦經司法院79年10月16日（79）秘台廳（1）字第02162號函釋在案。然分割共有物之訴既為形成之訴，則必須以法院判決形成之，依其性質原不得成立訴訟上和解，而訴訟法上和解分割，乃係基於當事人協議，以自治方式解決其分割方法，此種非由法院以裁判所為之分割，應不生既判力，故分割共有物成立訴訟上和解者，無從逕依和解筆錄消滅共有權及取得單獨所有權之效力。抑且，判決為法院對於訴訟事件所為公的意思表示，調解或和解為當事人就訴訟上之爭執互相讓步而成立之合意，其本質並非相同，故形成判決所生之形成力，無由當事人以調解或和解之方式代之。從而，在調解或訴訟上和解分割共有不動產者，僅生協議分割之效力，非經辦妥分割登記，不生喪失共有權及取得單獨所有權之效力，最高法院58年台上字第1502號判例足參。是以上訴人指稱分割共有物和解筆錄具有對世效力云云，容屬有誤，尚無足採。（粗體字為本文所強調）

鑒於行政訴訟常與公益具有密切關係，尤其是法院於執行其依法審判之職務時，做為依法行政原則之監控（審查）者，本應依職權查明事實，不受當事人主張之拘束（本法第125條第1項參照），正確適用法規，作出公正、合法且適當之裁判，特別是在撤銷訴

訟，係以行政機關行政處分之違法性及是否侵害人民之權益做為法院判決之（訴訟）標的，立法者鑑於此種訴訟類型與公益密切相關，是以特別規定法院應依職權調查證據，並不受當事人自認之拘束（本法第133條、第134條參照），因此，於撤銷訴訟是否能容許作為被告之行政機關和原告合意成立和解以終結訴訟，而使該案件不再受法院審查行政機關是否正確認定事實適用法規而遵守依法行政之要求，並非全無疑義¹¹¹。就此問題，於日本係以否定說為通說¹¹²，德國之文獻，則認為無論於何種訴訟類型皆有成立訴訟和解之可能，故縱使在撤銷訴訟，於不違反實體法規規定之要件下，當事人仍可締結訴訟和解以終結訴訟，惟如前所述，依德國行政法院法之規定，訴訟和解至多僅具執行力，並未具有確定判決或準確定判決之效力，由於法律規定之差異，應不能執該國就此之見解作為支持當事人於撤銷訴訟可締結訴訟和解之理由。

本法第222條規定，和解成立者，其效力準用第213條、第214條及第216條之規定，由於第216條規定為：「I. 撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力。II. 原處分或決定經判決撤銷後，機關須重為處分或決定者，應依判決意旨為之。III. 前二項判決，如係指摘機關適用法律之見解有違誤時，該機關即應受判決之拘束，不得為相左或歧異之決定或處分。IV. 前三項之規定，於其他訴訟準用之。」，若單從第222條之準用範圍包含第216條，主要是第1項與第2項之規定，似乎可認為撤銷訴訟亦得成立訴訟和解。然而，若從訴訟法之本質探討，撤銷訴訟之聲明係請求法院以形成判決撤銷被告機關之行政處分，並非由被告機關自行撤銷，依訴訟標的理論之訴訟法說，此聲明屬於訴訟標的之要素，而依實體法說，原告訴請撤銷行政處分創設、變更或消滅之實

111 參見徐瑞晃，行政訴訟撤銷之訴在訴訟上之和解，收於：台灣行政法學會編，行政契約與新行政法，頁327-329（2002年）。

112 參見徐瑞晃（註111），頁323。

體法律關係或形成權作為訴訟標的，則行政機關在依法行政之要求下，是否對此等訴訟標的（尤其處分之合法性與否）享有處分權，而得締結和解，實有深入探討之餘地。依實務絕大多數之見解，皆認為於形成訴訟，當事人若成立和解，僅屬實體法之和解，不能認為具有訴訟和解之性質，因而否定於形成訴訟得成立訴訟和解。茲舉著名之中科四期開發訴訟案之和解為例。

於臺北高等行政法院102年訴更一字第28號環評法事件中：

被告環保署與原告等30人，以及參加人科技部中部科學工業園區管理局（下稱中科管理局）達成和解，承諾後續中部科學工業園區第四期（二林園區）（下稱二林園區）開發案（下稱中科四期開發計畫）環評作業程序將依判決意旨及本和解方案辦理。一、被告環保署及參加人中科管理局應於和解成立後1個月內，將本案訴訟和解方案及最高行政法院102年度判字第70號判決摘要（如附件1），刊登被告環保署、參加人中科管理局及科技部之機關網站首頁，使一般民眾可以點入，期間為2個月。二、中科四期開發計畫於被告環保署做成第二階段環評審查結論，並公告環評報告書及審查結論摘要前，參加人中科管理局承諾在二林園區內不再進行發包施工，亦不核准新進廠商進駐，但已發包並正在施工之工程（明細如附件2）得繼續進行、已進駐廠商愛民衛材股份有限公司（統一編號：xxx）得繼續營運；另為因應天然災害之公共安全、防災相關工程亦不在此限。三、參加人中科管理局於中科四期開發計畫辦理第二階段環評時，應同意將下列項目納入範疇界定之評估項目：（一）污水能否達到零排放及其期程。（二）使用多介質模式評估中科四期開發計畫營運後，所可能產生之空氣污染對當地居民（園區周圍10公里×10公里之區域面積）之健康風險影響。（三）對相思寮聚落進行流行病學

調查。四、被告環保署於召開中科四期開發計畫第二階段環評範疇界定會議時，應通知原告，原告如有建議應評估項目，參加人中科管理局應儘可能同意納入評估。五、參加人中科管理局同意替相思寮聚落（二林鎮）等19戶居民（如附件3清冊）鋪設自來水管線，鋪設費用由參加人中科管理局負擔，且參加人中科管理局應協調自來水公司同意供應生活用水。另參加人中科管理局應就相思寮專案讓售之耕地，興建該耕地之農路與水路，以利農民之農機進出及取水。六、參加人中科管理區承諾就中科四期開發計畫研議成立生技專區（基因改造、疫苗研發製造除外）之可行性，如研議結果為可行，得將第二階段基地（即彰129線道以西區域，詳如附件4圖示）作為生技專區，且應於第一階段基地內已取得建造執照之進駐廠商所使用之開發面積，已達第一階段基地總可供出租面積80%以上時，第二階段基地始能進行開發（污水下水道系統除外）。七、被告環保署與參加人中科管理局同意，如有違反本和解方案之約定者，原告等得以本和解方案作為強制執行之名義，被告環保署或參加人中科管理局自願依行政程序法第148條規定接受強制執行（如附件5、6）。八、本和解方案成立後，原告本案其餘請求拋棄；並同意撤回臺北高等行政法院102年訴字第01614號行政訴訟案且促請同案其他原告撤回該案訴訟。九、訴訟費用各自負擔。（粗體字為本文所強調）

經詳細審酌和解內容，依和解內容之第8點約定，原告等人願撤回起訴，以及第7點，被告與參加人如有違約，本和解得為執行名義之協議，應可發現關於本件和解之性質，顯然並非行政訴訟法第219條規定之訴訟和解，而是行政程序法第136條之和解，蓋訴訟和解所具有之訴訟法效果即是終結訴訟，而不應由原告撤回起訴，

使訴訟繫屬消滅，蓋訴訟繫屬一消滅，和解即無從發生準確定判決之效力，再者，訴訟和解之效力既然準用確定判決之效力，若屬訴訟和解，即不須再約定違約時，他方得依本和解方案作為強制執行之名義，而被告環保署或參加人中科管理局自願依行政程序法第148條規定接受強制執行。由以上分析可知，臺北高等行政法院就102年訴更一字第28號環評法事件所成立之和解並不屬於行政訴訟法規定之訴訟和解，僅是行政程序法之和解。

然而弔詭的是，目前行政訴訟和解之案件有相當部分卻是撤銷訴訟，不禁令人懷疑，行政法院之法官是否皆確實審查當事人之和解針對訴訟標的？此外，其對於訴訟標的是否有處分權？最後，訴訟和解有無妨礙公益之維護？特別是於原告請求撤銷課稅處分之撤銷訴訟，就課稅基礎之事實認定在稅捐機關和納稅義務人之間有爭議時，是否得締結和解，不無疑問。依「稅捐稽徵機關稅務案件協談作業要點」第2點之規定：「稅務案件有下列情形之一，稽徵機關得與納稅義務人協談：（一）稽徵機關於審查階段中，就課稅事實之認定或證據之採認，有協談之必要者。（二）復查、依訴願法第58條第2項規定由原處分機關重新審查或經行政救濟撤銷重核案件，對課稅事實之認定或證據之採認，徵納雙方見解歧異者。」而依第10點規定：「協談案件應將協談經過及結果製作協談紀錄，載明下列事項，並由所有參加協談人員簽章：（一）協談日期、起訖時間及地點。（二）納稅義務人、其代理人及輔佐人姓名、身分證統一編號、住所或居所及聯絡電話。（三）納稅義務人為機關、團體或事業者，其代表人或管理人姓名、身分證統一編號、住所或居所、聯絡電話及其與機關、團體或事業之關係。（四）其他參加協談人員之姓名、職稱及所屬單位。（五）協談要點。（六）協談結果。」但此項協談結果依第13條之規定：「依本要點達成之協談結果，經稽徵機關簽報核定或簽提復查委員會之協談案件，除有下列情形之一外，稽徵機關應儘量遵照協談結果辦理：（一）協談之成

立，係以詐術或其他不正當方法達成者。(二)協談成立後，發現新事實或新證據，影響課稅之增減者。」(粗體字為本文所強調)

由於稽徵機關對於協談結果僅是儘量遵照協談結果辦理，並非如契約當事人般受拘束，對於稽徵機關及納稅義務人而言，縱使雙方當事人意見一致，由於(至少)稽徵機關對協談結果欠缺受拘束之意思，即不能認為稽徵機關和納稅義務人已締結行政法上之和解契約。拙見認為，若稅法對於課稅基礎事實不明之情形設有特別之推估規定時，雖應先適用該等規定，例如所得稅法第83條第1項規定：「稽徵機關進行調查或復查時，納稅義務人應提示有關各種證明所得額之帳簿、文據；其未提示者，稽徵機關得依查得之資料或同業利潤標準，核定其所得額。」同條第3項規定：「納稅義務人已依規定辦理結算申報，但於稽徵機關進行調查時，通知提示有關各種證明所得額之帳簿、文據而未依限期提示者，稽徵機關得依查得之資料或同業利潤標準核定其所得額；嗣後如經調查另行發現課稅資料，仍應依法辦理。」惟，假如稅捐稽徵機關適用該等規定後仍無法確定事實，例如欠缺資料或同業利潤標準或與納稅義務人就推估之事實有爭議，或對於課稅基礎事實不明並無特別之推估規定時，應許稅捐機關和納稅義務人於符合行政程序法第136條規定之要件下締結和解契約以排除該項因事實不明所生之爭議¹¹³。但應注意者乃是，因撤銷訴訟之訴訟標的應係原告主張被告機關將特定之生活事實適用特定法規所為之行政處分違法侵害原告之權益，而請求法院以判決將其撤銷之訴訟上請求(依三分肢說之理論)，若僅就課稅基礎之原因事實締結和解，因其並非針對訴訟標的，且依前述拙見，撤銷訴訟因屬形成訴訟，性質上不許成立訴訟和解，是以

¹¹³ Vgl. BFH, NVwZ 1985, S. 863. 依司法院釋字第217號解釋之見解，憲法第19條規定人民有依法律納稅之義務，係指人民僅依法律所定之納稅主體、稅目、稅率、納稅方法及納稅期間等項而負納稅之義務。至於課稅原因事實之有無及有關證據之證明力如何，乃屬事實認定問題，不屬於租稅法律主義之範圍。

應認為僅就該部分成立訴訟外之和解，但實務常將其視為訴訟和解者，例如臺北高等行政法院89年度訴字第1290號綜合所得稅之案件，當事人成立之訴訟和解內容如下：

一、有關原告82年度綜合所得稅事件，被告88年11月24日北區國稅法第88057208號復查決定書，原核定有關執行業務所得為新臺幣（下同）六百九十七萬五千八百九十二元，確認金額變更為五百七十四萬八千一百三十四元，其中有關82年度執行業務所得勞保掛號費收入部分，確認變更金額為三百二十九萬三千五百元（與原核定差額：一百零八萬八千九百三十一元），公保掛號費收入部分，原核定金額為六十七萬一千七百五十七元，確認金額為五十三萬二千九百三十元（與原核定差額：十三萬八千八百二十七元），以上，雙方同意原告八十二年度執行業務所得部分，准予再追減公、勞保掛號費收入共計一百二十二萬七千七百五十八元。二、兩造其餘聲明及請求全部拋棄。三、訴訟費用由原告負擔。

與上揭相類之和解案件似乎不少¹¹⁴，此種案件實際上係針對課稅基礎之原因事實締結和解，因其並非針對撤銷訴訟之訴訟標的¹¹⁵，特別是當事人如何處置原課稅處分，和解筆錄並未觸及，且法院亦未說明租稅法律之下，稅捐稽徵機關就此等事實有如何之處分權，此和解是否不妨礙公益，故法院之和解處置頗有商榷之餘地¹¹⁶。

114 參見徐瑞晃（註111），頁340-343。

115 相同見解，徐瑞晃（註111），頁333；盛子龍，當事人對訴訟標的之處分權作為行政訴訟上和解之容許性要件，台灣本土法學雜誌，71期，頁62（2005年）。

116 當然在租稅爭訟事件，往昔實務上多採「爭點」主義，或許基於此理論，而將課稅基礎事實當作訴訟標的，然而爭點理論將同一課稅基礎事實適用同一法規產生之同一納稅義務，將組成基礎事實之個別事實當成訴訟標的，使同

此外，若課稅基礎之法律關係不明，似不應許稅捐機關和人民訂立和解契約，蓋稅捐機關本於租稅法律原則，對於課稅基礎之法律關係確實存在與否，應依職權調查，若不能確定，即不能適用以該法律關係為要件之法規，俾符合依法行政（納稅）之要求，不應由當事人以讓步之方式締結和解契約，違反稅法之規定創設變更或消滅稅法之權利、義務關係¹¹⁷，且其亦非訴訟標的，故不得成立訴訟和解。

（二）和解之確定力（本法第213條與第214條之準用）

依本法第222條之規定，和解成立之效力亦準用本法第213條，第213條規定：「訴訟標的於確定之終局判決中經裁判者，有確定力。」暫且不論訴訟和解準用確定力之範圍如何，首先應闡明確定力之概念，然後始能決定如何準用。一般而言，判決之效力涉及外部或形式確定力（*äußere od. formelle Rechtskraft*）與內部或實質確定力（*innere od. materielle Rechtskraft*），實質確定力又涉及事物的（客觀）確定力和人的（主觀）確定力¹¹⁸，此外，又依不同判決類型而具有不同效力，詳言之，判決依其類型具有執行力¹¹⁹、形成力¹²⁰或確認力¹²¹，而不論給付判決、形成判決或確認判決，皆具

一課稅義務得因個別事實多次提起獨立訴訟，違背法理，應不足採，同說例如陳清秀，稅法總論，8版，頁781-785（2014年）。納稅者權利保護法於106年12月28日施行後，依第21條第1項規定：「納稅者不服課稅處分，經復查決定後提起行政爭訟，於訴願審議委員會決議前或行政訴訟事實審言詞辯論終結前，得追加或變更主張課稅處分違法事由，受理訴願機關或行政法院應予審酌。其由受理訴願機關或行政法院依職權發現課稅處分違法者，亦同。」可見立法者顯已不採爭點主義，而趨向總額主義。

¹¹⁷ 同說參見，林明鏘，行政契約，收於：翁岳生編，行政法（下冊），2版，頁654（2000年）。

¹¹⁸ Vgl. Peter Hartmann, in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann (Hrsg.), Zivilprozessordnung, 72. Aufl., 2014, Einführung vor § 322.

¹¹⁹ Vgl. Seiler (Fn. 40), § 704 Rn. 1.

¹²⁰ Vgl. Seiler (Fn. 40), Vorbem. § 253 Rn. 7.

¹²¹ Vgl. Seiler (Fn. 40), Vorbem. § 253 Rn. 4.

有確認力¹²²。茲將確定力分述如下：

1. 形式確定力

具有形式確定力者並非僅終局判決，一切裁判，不論是終局裁判、得獨立抗告之裁定或須附隨於終局判決進行救濟之裁判（中間裁判或先決裁判）¹²³，皆可發生形式確定力，但本文僅針對終局判決論述。

訴訟之目的在於彌平當事人之紛爭，並確定權利義務關係，藉以維持法律秩序，當法院作出終局判決後，若當事人已無法依通常之救濟程序（上訴）請求將之廢棄時，該判決即發生所謂之形式確定力¹²⁴。形式確定力重在程序面，阻斷當事人再提起上訴請求廢棄原判決之機會，藉以維護司法威信、法律（權利義務）之安定性與法律和平，並避免判決之外部存在處於浮動而有被廢棄之可能性以及訴訟程序未能終結之狀態¹²⁵，其乃是實質確定力之先決條件¹²⁶。判決確定之時期，依本法第212條規定：「I. 判決，於上訴期間屆滿時確定。但於上訴期間內有合法之上訴者，阻其確定。II. 不得上訴之判決，於宣示時確定；不宣示者，於公告主文時確定。¹²⁷」據此規定，當事人雖提起上訴，若其上訴不合法者，則判決仍於上訴期間屆滿時確定。又依本法第241條之規定：「提起上

¹²² Vgl. *Jauernig/Hess* (Fn. 1), § 34 Rn. 1 ff.

¹²³ Vgl. *Leo Rosenberg/Karl Heinz Schwab/Peter Gottwald*, *Zivilprozessrecht*, 16. Aufl., 2007, § 149 Rn. 1.

¹²⁴ Vgl. *Seiler* (Fn. 40), § 704 Rn. 2.

¹²⁵ Vgl. *Jauernig/Hess* (Fn. 1), § 62 Rn. 4; *Seiler* (Fn. 40), § 322 Rn. 1.

¹²⁶ Vgl. *Hartmann* (Fn. 118), Einführung vor § 322 Rn. 1; *Jauernig/Hess* (Fn. 1), § 62 Rn. 9; *Seiler* (Fn. 40), § 322 Rn. 1; 給付判決原則上亦於形式確定時發生執行力，但有假執行宣告之判決則不待形式確定即有執行力。

¹²⁷ 德國民事訴訟法之類似規定為第705條：„Die Rechtskraft der Urteile tritt vor Ablauf der für die Einlegung des zulässigen Rechtsmittels oder des zulässigen Einspruchs bestimmten Frist nicht ein. Der Eintritt der Rechtskraft wird durch rechtzeitige Einlegung des Rechtsmittels oder des Einspruchs gehemmt.“。

訴，應於高等行政法院判決送達後二十日之不變期間內為之。但宣示或公告後送達前之上訴，亦有效力。」此外，對終局判決有上訴權之各當事人之上訴期間應分別計算，須全部當事人皆已屆滿時，判決始確定，職是之故，必要共同訴訟人須全部不得上訴時，判決（若他造當事人亦喪失上訴權）始生形式確定力。對於具有形式確定力之判決，當事人或第三人僅得依再審之訴或重新審理等特別（例外）途徑尋求救濟¹²⁸。

2. 實質確定力

首先，依德國通說見解，應與判決之實質確定力區別者乃是執行力、形成力、判決之構成要件效力（Tatbestandswirkung; 或稱反射效力Reflexwirkung）¹²⁹、從參加效力以及羈束力¹³⁰。判決之構成要件效力係因訴訟法或實體法之規定而生，與當事人（原告）之聲明無關，並非訴訟標的，故不屬於法院審理裁判之範圍，實體法之反射效力例如民法第137條第2項與第3項規定：「II. 因起訴而中斷之時效，自受確定判決，或因其他方法訴訟終結時，重行起算。III. 經確定判決或其他與確定判決有同一效力之執行名義所確定之請求權，其原有消滅時效期間不滿五年者，因中斷而重行起算之時效期間為五年。」關於消滅時效中斷以及時效期間延長之結果係因法律規定；訴訟法之範例如民事訴訟法第395條第2項規定：「法院廢棄或變更宣告假執行之本案判決者，應依被告之聲明，將其因假執行或因免假執行所為給付及所受損害，於判決內命原告返還及賠償，被告未聲明者，應告以得為聲明。」據此規定，凡是宣告假執行之本案判決遭廢棄或變更者，原告將負有返還及賠償之義務¹³¹。

¹²⁸ Vgl. Jauernig/Hess (Fn. 1), § 62 Rn. 7.

¹²⁹ 亦有學者將反射效力認為係非確定判決效力所及第三人之權利義務受確定判決影響之效力。參見陳計男，民事訴訟法論（下冊），增訂3版，頁85（2005年）；姜世明，民事訴訟法（下冊），修訂4版，頁285（2016年）。

¹³⁰ Vgl. Seiler (Fn. 40), § 322 Rn. 2; Völzmann-Stickelbrock (Fn. 107), § 322 Rn. 4-8.

¹³¹ Vgl. Jauernig/Hess (Fn. 1), § 62 Rn. 10.

此種構成要件效力亦有稱之為確定判決之附隨效力者¹³²。惟本文僅就判決之實質確定力進行探討。

（1）實質確定力之概念與性質

確定判決之效力主要可區分為主觀與客觀兩部分，前者涉及人之效力，後者則針對訴訟標的。實質確定力在臺灣文獻上又常稱為既判力¹³³，係指法院於確定終局判決所判斷之內容，發生拘束法院及當事人之效力。關於實質確定力之性質，德國文獻上有不同見解，基本上可區分為實體法說和訴訟法說，而各說又有歧異觀點，茲簡述之如下：

A. 實體法說

本說區分新舊二說，舊說認為判決之實質確定力應歸諸於實體法之作用，判決之內容應和實體權利一致，職是之故，若確定判決發生錯誤，將「創設」新權利義務，因此，實際不存在之權利若經確定判決認為存在，該權利將被創設，而實際存在之權利若經確定判決認為不存在，該權利即因而消滅。換言之，確定判決之確定力「認證」既存之權利義務狀態，並拘束當事人。若原當事人提起新訴，後訴之審理法官應受既存之實體權利地位（實體法）拘束，藉以貫徹實體權利之既存狀態並保護之¹³⁴。新說（由Rudolf Pohle所倡）則認為，確定判決就其判決內容之正確性以及其確認之法律地位具有不可推翻之正確性推定¹³⁵。

¹³² 參見陳計男（註129），頁84-85；姜世明（註129），頁285。

¹³³ 既判力為日本法律用語，我國亦多有沿用者，然因其概念未能完整涵蓋判決之確定力，且國內文獻就其概念論述亦不一致，例如有將既判力又區分實質既判力與形式既判力者（例如陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（中冊），2005年修訂四版，頁594），故本文不採用。

¹³⁴ Vgl. Jauernig/Hess (Fn. 1), § 62 Rn. 4; Seiler (Fn. 40), § 322 Rn. 5; Peter Gottwald, in: Rauscher/Krüger (Hrsg.), Münchener Kommentar ZPO, Bd. I, 4. Aufl., 2013, § 322 Rn. 7.

¹³⁵ Gottwald (Fn. 134), § 322 Rn. 8; Völzmann-Stickelbrock (Fn. 107), § 322 Rn. 3.

B. 訴訟法說

訴訟法說主張實體法說之主張存在本質錯誤，蓋因確定判決之效力僅及於當事人，不及於第三人，故錯誤判決對於對世權不能發生創設作用，詳言之，具有對世效力之權利，例如所有權、繼承權等等，縱使因錯誤判決認定不存在，該權利亦不消滅，反之，無權之人縱使因錯誤判決誤認為權利人，其亦不能向第三人主張權利¹³⁶。本說認為，除某些特殊形成訴訟外，法官之任務並非在於變更或創設當事人間之法律地位，而是就現存之法律關係進行裁判。但訴訟法說之論點又有歧異而分為新舊二說，舊說（Hellwig）認為實質確定力之作用在於禁止後訴之法官做出與確定判決歧異之認定、裁判，換言之，確定判決之實質確定力僅生對後訴法官之拘束力，但並不阻礙原當事人就同一事件重複起訴，法院再度實體審理並做出判決。但新說（Leo Rosenberg, Eduard Bötticher）則認為，實質確定力既然對法院和當事人就判決確認之法律效果發生拘束力，此時即不應許可當事人再度就同一事件重新起訴請求實體審判，原告之新訴應欠缺權利保護之訴訟要件，法院不許實體審判而應以起訴不合法程序上駁回。此說創立一事不再理原則，而為德國目前實務、通說所採¹³⁷。

C. 小結

本文認為，訴訟之目的既涉及實體權利義務爭議之解決，法院之判決確定後，不但司法威信應予維護，不應率爾重複審判，而且實體判決又針對當事人之實體法權利義務進行確認，是以判決確定力不應單從實體法或訴訟法觀察，而應綜合兩者認定其性質，換言

¹³⁶ Vgl. *Jauernig/Hess* (Fn. 1), § 62 Rn. 6, 7.

¹³⁷ Vgl. *Seiler* (Fn. 40), § 322 Rn. 7; *Gottwald* (Fn. 134), § 322 Rn. 9; *Grunsky* (Fn. 41), § 47 III 2, S. 494 ff.; *Völzmann-Stickelbrock* (Fn. 107), § 322 Rn. 3; *Jauernig/Hess* (Fn. 1), § 62 Rn. 8 ff.

之，判決確定力不但有其實體法作用，確認當事人爭議之實體法律關係，縱使可能誤判，在未依法廢棄之前，法院及當事人仍應尊重其效力並受拘束，因此應同時兼具訴訟法之效力，亦即禁止重複就同一事件（訴訟標的）進行實體審判¹³⁸。綜而言之，實質確定力之理論基礎乃是確定判決在訴訟法上發生拘束當事人和所有受理後訴之法官，於其（後訴）判決內容不得為相反之認定。為達到此目的之方法則為禁止當事人重複起訴以及法院重複裁判（一事不再理）。此種訴訟法之效果對當事人之實體法律關係亦有影響，因當事人間之權利義務即以確定判決所認定者為準。而且實質確定力在某種範圍內更直接發生實體法上之效力，例如形成判決因其形成力具有創設、變更、消滅實體法律關係之效力。是否有實質確定力存在，法院應依職權調查，不受當事人合意之拘束。

（2）實質確定力之客觀範圍

依據本法第213條之規定，實質確定力係以確定終局判決中經裁判之訴訟標的做為其客觀範圍¹³⁹，法院縱使對訴訟標的外之事項作出判斷，除非法有特殊規定，否則就該部分亦不生實質確定力¹⁴⁰。換言之，實質確定力之內涵和所及之範圍係取決於訴訟標的之概念，因此，於探討判決之確定力時，必須先確定訴訟標的。關於訴訟標的之理論，可參照前述。若以三分肢說為準，則確定力所及之範圍雖包含個案之生活事實，但生活事實須以原告主張或法院判決適用之實體法規為界限，並依原告之訴之聲明確定之。

A. 實質確定力之內涵

一般而言，實質確定力之客觀範圍雖以判決主文所判斷之訴訟

138 相同見解參見姜世明（註129），頁289-290。

139 Vgl. *Völzmann-Stickelbrock* (Fn. 107), § 322 Rn. 28.

140 Vgl. *Jauernig/Hess* (Fn. 1), § 63 Rn. 3.

標的為限¹⁴¹，然而，訴訟標的極少完整顯現在主文，若主文不明確，特別是駁回原告之訴時，仍應結合理由判斷訴訟標的¹⁴²。但判決理由若非對於訴訟標的之判斷，除有特別規定外，不生實質確定力，不論是對原告提出之攻擊方法或被告提出之防禦方法所做之判斷，皆同¹⁴³。職是之故，關於判決之訴訟標的為何，仍須依判決內容整體認定。判決理由發生實質確定力之例外，例如民事訴訟法第400條第2項規定：「主張抵銷之請求，其成立與否經裁判者，以主張抵銷之額為限，有既判力。」此乃是判決理由具有實質確定力之例外。抵銷生實質確定力之要件：1. 原告之債權存在；2. 被告抵銷之主張形式上合法；3. 被告主張之債權存在、不存在經法院判斷；4. 實質確定力之範圍以原告主張權利之範圍為限¹⁴⁴。然而，行政訴訟法第213條無此規定，民事訴訟法第400條第2項之規定是否可準用於行政訴訟，仍有爭議。但當事人於訴訟和解中之抵銷，似應認為不生確定力。

a. 各種判決皆具有確認力

不論原告提起之訴訟類型為形成、給付或確認訴訟，法院作出之判決於確定後皆具有確認效力。在確認訴訟，不論原告勝訴或敗訴，法院皆作出確認判決，確認原告訴請確認之標的存在或不存在。原告提起給付訴訟與形成訴訟時，不論原告勝訴或敗訴，法院之判決皆對於原告主張之權利存在與否作出確認，於原告勝訴時，除確認原告主張之權利（請求權或形成權）存在外，並作成具執行

141 最高法院73年台上字第3292號民事判例：「民事訴訟法第四百條第一項規定確定判決之既判力，惟於判決主文所判斷之訴訟標的，始可發生。若訴訟標的以外之事項，縱令與為訴訟標的之法律關係有影響，因而於判決理由中對之有所判斷，除同條第2項所定情形外，尚不能因該判決已經確定而認此項判斷有既判力。」

142 Vgl. Jauernig/Hess (Fn. 1), § 63 Rn. 25.

143 Vgl. Jauernig/Hess (Fn. 1), § 63 Rn. 22.

144 Vgl. Jauernig/Hess (Fn. 1), § 63 Rn. 23.

力之給付判決，或具形成力之形成判決，於原告敗訴時，則確認其主張之權利不存在，屬於確認判決¹⁴⁵。據此，最高行政法院97年12月份第3次庭長法官聯席會議（二）決議認為：

課予義務訴訟之訴訟標的，依行政訴訟法第5條規定，應為「原告關於其權利或法律上利益，因行政機關違法駁回其依法申請之案件，或對其依法申請之案件不作為致受損害，並請求法院判令被告應為決定或應為特定內容行政處分之主張」。又依同法第213條規定，上開課予義務訴訟之訴訟標的，於確定之終局判決中經裁判者，有確定力。是原告提起課予義務訴訟如經判決駁回確定者，該判決之確定力（既判力）不僅及於確認「原告對於請求作成其所申請行政處分依法並無請求權」，且及於「被告機關原不作為或否准處分為合法」、「不作為或否准處分並未侵害原告之權利或法律上利益」之確認；若行政法院依行政訴訟法第200條第3款規定判決原告勝訴確定者，該判決之既判力，不僅及於確認原告對被告依法有作成所請求行政處分之權利，及命令被告機關作成特定內容之行政處分，且及於被告機關之否准處分為違法並侵害原告之權利或法律上利益之確認；如行政法院依行政訴訟法第200條第4款規定判決原告勝訴確定者，該判決就原告對被告是否有依法作成所請求行政處分之權利雖未加以確認，亦未命令被告機關作成特定內容之行政處分，惟該判決之既判力，仍及於系爭否准處分或不作為為違法並侵害原告之權利或法律上利益之確認。

b. 給付判決之實質確定力是否包含執行力？

由於德國民事訴訟法文獻幾乎皆將實質確定力和執行力明確區別，此區別雖亦屬正確可採，但因此卻產生疑義者乃是給付判決之實質確定力是否當然含有執行力，抑或係因法律另設之規定，例如

¹⁴⁵ Vgl. Peter Arens/Wolfgang Lücke, Zivilprozeßrecht, 7. Aufl., 1999, § 27 Rn. 328.

本法第305條規定：「I. 行政訴訟之裁判命債務人為一定之給付，經裁判確定後，債務人不為給付者，債權人得以之為執行名義，聲請地方法院行政訴訟庭強制執行。II. 地方法院行政訴訟庭應先定相當期間通知債務人履行；逾期不履行者，強制執行。III. 債務人為中央或地方機關或其他公法人者，並應通知其上級機關督促其如期履行。IV. 依本法成立之和解，及其他依本法所為之裁定得為強制執行者，或科處罰鍰之裁定，均得為執行名義。（粗體字為本文所強調）」始賦予確定給付判決執行力？關於此問題，由於本文就訴訟標的理論係採訴訟法說（之三分肢說），而關於實質確定力之本質採實體與訴訟並具之綜合說，故原告之訴之聲明亦屬於訴訟標的之要素，其係請求國家司法權命被告應履行其給付義務，法院據此作出之給付判決不但同時確定當事人之權利義務（原告之請求權和被告之給付義務），同時亦包含對被告得強制執行之給付命令（Leistungsbefehl）¹⁴⁶，並使原告取得強制執行請求權，是以拙見認為給付判決確定時，除非法律規定不得強制執行者外¹⁴⁷，依其本質當然含有執行力，而非因為本法第305條之規定所賦予，該規定實質上應僅具宣示作用而已，尤其是依強制執行法¹⁴⁸第4條之用語「強制執行，依左列執行名義為之」，更可推出確定判決、訴訟和解等已具有執行名義之作用¹⁴⁹，並非該條賦予執行名義之作用。此

¹⁴⁶ Vgl. Arens/Lüke (Fn. 145), § 27 Rn. 328; Grunsky (Fn. 41), § 39 II, S. 394 f.; Seiler (Fn. 40), vor § 253 Rn. 3.

¹⁴⁷ 例如強制執行法第128條第2項規定：「前項規定，於夫妻同居之判決不適用之。」

¹⁴⁸ 強制執行法第306條：「I. 地方法院行政訴訟庭為辦理行政訴訟強制執行事務，得囑託民事執行處或行政機關代為執行。II. 執行程序，除本法別有規定外，應視執行機關為法院或行政機關而分別準用強制執行法或行政執行法之規定。III. 債務人對第一項囑託代為執行之執行名義有異議者，由地方法院行政訴訟庭裁定之。」

¹⁴⁹ 強制執行法第4條：「I. 強制執行，依左列執行名義為之：一、確定之終局判決。二、假扣押、假處分、假執行之裁判及其他依民事訴訟法得為強制執行之裁判。三、依民事訴訟法成立之和解或調解。四、依公證法規定得為強制執行之公證書。五、抵押權人或質權人，為拍賣抵押物或質物之聲請，經法

外，亦可藉由原告請求被告作成意思表示之給付判決說明，依強制執行法第130條規定：「I. 命債務人為一定之意思表示之判決確定或其他與確定判決有同一效力之執行名義成立者，視為自其確定或成立時，債務人已為意思表示。II. 前項意思表示有待於對待給付者，於債權人已為提存或執行法院就債權人已為對待給付給予證明書時，視為債務人已為意思表示。公證人就債權人已為對待給付予以公證時，亦同。」據此規定，命債務人為一定之意思表示之判決一經確定，並非不具執行力，而是視為已經執行完畢¹⁵⁰，雖然事實上債權人並未聲請強制執行，但該判決亦已於發生形式確定力時執行完畢。惟若無此規定，仍應認為原告得聲請強制執行。

c. 形成判決之實質確定力是否包含形成力？

於原告提起形成訴訟時，若原告勝訴，法院應作出形成判決，依原告之聲明，在判決主文宣示創設、變更或消滅當事人間權利義務關係，此判決於發生形式確定力時直接創設、變更或消滅當事人間之權利義務關係，而具有形成力。由於當事人間之權利義務關係於判決確定時立即變動，原告訴訟之目的已經實現，故無執行之問題¹⁵¹。由於形成力之強大作用，僅代表國家行使司法權之法院始能

院為許可強制執行之裁定者。六、其他依法律之規定，得為強制執行名義者。II. 執行名義附有條件、期限或須債權人提供擔保者，於條件成就、期限屆至或供擔保後，始得開始強制執行。III. 執行名義有對待給付者，以債權人已為給付或已提出給付後，始得開始強制執行。」

150 同說，認為屬特殊形態之強制執行者，*Grunsky* (Fn. 41), § 38 II 3, S. 376. 認為無執行力之不同見解，陳計男（註129），頁84。

151 最高行政法院94年度裁字第317號民事裁定：「按『撤銷判決確定者，關係機關應即為實現判決內容之必要處置。』為行政訴訟法第304條所明定，並無如同法第305條第1項所定得向高等行政法院聲請強制執行之規定。蓋撤銷原處分之判決係屬形成判決，行政處分經判決撤銷確定後，溯及失其效力，原不生強制執行問題。本件抗告人據以聲請強制執行之本院91年度判字第2318號判決，由其主文載明『原判決廢棄。訴願決定及原處分均撤銷』，可知僅係將相對人原處分撤銷，並未命相對人對抗告人為一定之給付，為一撤銷判決，已使原違法登記處分溯及失其效力，本無庸向高等行政法院聲請強制執行。」

作出形成判決。訴訟當事人締結之契約，特別是訴訟（和解）契約不能具有此種效力。但是形成判決之形成力和實質確定力之關係如何，則存有不同見解。如同上述，拙見既採綜合說，而且法院之形成判決係依原告之訴之聲明而作成，且於發生形式確定力時，當事人間之實體法法律地位已經如判決主文發生變動，並非僅具訴訟法性質，而且該形成力亦非僅具當事人相互間之效力，而是具有對世效力¹⁵²。許多採訴訟法說之德國學者認為實質確定力和形成力無關，其中有認為在形成訴訟，實質確定力之標的乃是原告享有形成權之確認，而非形成力¹⁵³，或有學者認為對第三人而言，應是尊重形成判決所創設、變更或消滅當事人間權利義務關係之狀態，而非具有對世效力¹⁵⁴。但既然將原告之訴之聲明納為訴訟標的之要素，則在形成訴訟，法院作出之形成判決即是依原告之聲明，而且直接創設、變更或消滅當事人間之實體法律關係，此判決更具有對世效力，實應認為實質確定力包含形成力，此應屬自明之理，實不待煩言而可理解。

d. 一事不再理

確定判決之實質確定力既係以訴訟標的為其對象，若前後二訴之訴訟標的相同，則後訴應不合法，裁定駁回¹⁵⁵。依三分肢說之見解，確定判決對於訴訟標的，亦即判決基礎之社會生活事實、所適用之實體法規，以及當事人所為之訴之聲明範圍內發生其確定力¹⁵⁶。據此，若社會生活事實不同，因訴訟標的不同，即不受確定

152 Vgl. Seiler (Fn. 40), vor § 253 Rn. 6; Hartmann (Fn. 118), § 322 Rn. 43; Hans-Joachim Musielak, Grundkurs ZPO, 3. Aufl., 1995, Rn. 474; Grunsky (Fn. 41), § 48 II, S. 550.

153 Vgl. Jauernig/Hess (Fn. 1), § 65 Rn. 8; Hartmann (Fn. 118), § 322 Rn. 43.

154 Vgl. Völzmann-Stickelbrock (Fn. 107), § 322 Rn. 6; Gottwald (Fn. 134), § 322 Rn. 19.

155 Vgl. Seiler (Fn. 40), § 322 Rn. 11.

156 最高行政法院93年度判字第782號判決：「為訴訟標的之法律關係於確定終局判決中經裁判，該確定終局判決中有關訴訟標的之判斷，即成為規範當事人

力拘束，反之，如社會生活事實相同，且當事人、判決適用之實體法規及聲明皆同，因屬同一事件，即受實質確定力之拘束。再者，由於判決適用之實體法規亦屬訴訟標的之構成要素，職是之故，確定判決中所適用之實體法規若和新訴訟案件應適用之法規有異，即非同一訴訟標的。例如原告甲夜間燃放鞭炮遭被告乙環保機關裁罰，若乙先以製造噪音之規定處罰，但遭法院撤銷裁罰處分後，又以甲燃放鞭炮未清掃炮紙亂丟垃圾製造髒亂之規定裁罰，雖生活事實相同，惟因裁罰法規不同，即非同一案件。

此外，關於訴之聲明之同一性，應認為訴之聲明相同、相反（同一債權存在和不存在）或可互為代用（包括被涵蓋，例如同一債權之給付包含確認）者，皆屬於相同，因此，原告提起給付訴訟受敗訴判決確定者，若又依同一事實主張相同實體權利（法律關係）提起確認訴訟時，應認為違背確定判決之確定力（違背一事不再理）¹⁵⁷。但訴訟標的之先決關係或基礎關係¹⁵⁸、個別事實之確認（Tatsachenfeststellungen）¹⁵⁹、或（所有權）權利歸屬主體不同時，例如甲以乙為被告，確認某屋所有權屬於甲，乙則提起反訴確認該屋所有權屬於乙¹⁶⁰，訴訟標的並非相同。惟若物權經判決確定屬於甲，則乙提起確認所有權屬於乙之後訴為不合法，蓋前訴認為所有權屬於甲之確認（實質確定力）已經排除該物所有權歸屬他人之可能性¹⁶¹。又，若原告提起一部給付訴訟，經法院判決確定，其實質確定力所及之範圍是否包括未起訴之部分，文獻上存有爭議，

間法律關係之基準，嗣後同一事項於訴訟中再起爭執時，當事人即不得為與該確定判決意旨相反之主張，法院亦不得為與該確定判決意旨相反之判斷，其積極作用在避免先後矛盾之判斷，消極作用則在禁止重複起訴。」

157 Vgl. Jauernig/Hess (Fn. 1), § 62 Rn. 4, 5.

158 Vgl. Jauernig/Hess (Fn. 1), § 62 Rn. 17, 18.

159 Vgl. Seiler (Fn. 40), § 322 Rn. 19, 27; Völzmann-Stickelbrock (Fn. 107), § 322 Rn. 18; Jauernig/Hess (Fn. 1), § 62 Rn. 15, 16.

160 Vgl. Jauernig/Hess (Fn. 1), § 62 Rn. 6. 但BGH, NJW 1995, S. 968有不同見解。

161 Vgl. Jauernig/Hess (Fn. 1), § 62 Rn. 7.

關於此問題，應認為僅及於起訴之部分，未起訴之部分不受實質確定力所及¹⁶²。

(3) 實質確定力之主觀範圍

本法第214條規定：「I. 確定判決，除當事人外，對於訴訟繫屬後為當事人之繼受人者及為當事人或其繼受人占有請求之標的物者，亦有效力。II. 對於為他人而為原告或被告者之確定判決，對於該他人亦有效力。」茲將判決確定力之主觀範圍敘述如下：

A. 當事人、當事人之繼受人以及為當事人或其繼受人占有請求之標的物之人

判決實質確定力所及之主觀範圍以訴訟當事人為原則，蓋其作為訴訟之主體，藉由攻擊防禦方法之提出，請求法院作出裁判以維護其權益，理當尊重法院之確定判決而受拘束，此後亦不應再於其他訴訟持異議。當事人以外之第三人因未參與訴訟程序，為維護其訴訟權，原則上不受確定判決效力所及¹⁶³。

此外，訴訟標的之繼受人因承受訴訟標的而取得當事人之地位，故亦應受確定判決之拘束，繼受人包括一般繼受人和特定繼受人¹⁶⁴。前者若係繼承人，則係指判決確定後始發生之繼承，否則應依承受訴訟之規定處理，特定繼受人則指訴訟繫屬後發生之繼受¹⁶⁵。另應注意者，實務認為應分別訴訟標的為債權或物權而論，若係債權，須繼受訴訟標的者始為此之繼受人，但若訴訟標的係物權性質，因其具有對世效力，因物權常隨物之移轉而移轉，故單純繼受標的物者，亦屬此之繼受人¹⁶⁶。理論上應區分訴訟標的本身是

¹⁶² Vgl. Seiler (Fn. 40), § 322 Rn. 22; Jauernig/Hess (Fn. 1), § 62 Rn. 9 ff.

¹⁶³ Vgl. Jauernig/Hess (Fn. 1), § 63 Rn. 29.

¹⁶⁴ Vgl. Jauernig/Hess (Fn. 1), § 63 Rn. 30, 31.

¹⁶⁵ 民事訴訟法第254條關於當事人恆定之規定在此不予討論。

¹⁶⁶ 前最高法院42年台上字第1115號民事判例：「某乙移轉系爭房屋所有權於上

否具有對世效力或僅有對人之效力，若屬前者，則判決之確定力應及於所有人，若屬後者，則僅對當事人及其繼受人生效。此外，若訴訟標的涉及特定物者，為當事人或其繼受人占有請求之標的物之人乃是其主占有人，因係專為當事人或其繼受人之利益占有系爭標的物，並非以自主之意思占有（非為自己之利益而占有），故亦應受實質確定力之拘束，例如保管人、受寄人等，不包括承租人、典權人或質權人，蓋此等人係為自己之利益占有。

B. 訴訟擔當之被擔當人

在訴訟擔當之情形，不論法定訴訟擔當或任意訴訟擔當，被擔當人之訴訟實施權皆由擔當人於訴訟中行使，屬於實質之當事人，因此，本法第214條第2項乃規定，對於為他人而為原告或被告者之確定判決，對於該他人亦有效力。例如未被選定為選定當事人而脫離訴訟之其他當事人或受破產宣告之破產人¹⁶⁷。

訴人，已在被上訴人對某乙訴請拆屋交地事件之訴訟繫屬以後，既為上訴人所不否認，則被上訴人與某乙間拆屋交地之確定判決，依民事訴訟法第400條第1項之規定，對於就系爭房屋居於特定繼承之地位之上訴人，亦有效力。」、同院61年台再字第186號民事判例：「民事訴訟法第401條第1項所謂繼受人，依本院33年上字第1567號判例意旨，包括因法律行為而受讓訴訟標的之特定繼承人在內。而所謂訴訟標的，係指為確定私權所主張或不認之法律關係，欲法院對之加以裁判者而言。至法律關係，乃法律所定為權利主體之人，對於人或物所生之權利義務關係。惟所謂對人之關係與所謂對物之關係，則異其性質。前者係指依實體法規定為權利主體之人，得請求特定人為特定行為之權利義務關係，此種權利義務關係僅存在於特定之債權人與債務人之間，倘以此項對人之關係為訴訟標的，必繼受該法律關係中之權利或義務人始足當之，同法第254條第1項亦指此項特定繼受人而言。後者則指依實體法規定為權利主體之人，基於物權，對於某物得行使之權利關係而言，此種權利關係，具有對世效力與直接支配物之效力，如離標的物，其權利失所依據，倘以此項對物之關係為訴訟標的時，其所謂繼受人凡受讓標的物之人，均包括在內。本件訴訟既本於買賣契約請求辦理所有權移轉登記，自係以對人之債權關係為其訴訟標的，而訴外人某僅為受讓權利標的物之人，並未繼受該債權關係中之權利或義務，原確定判決之效力，自不及於訴外人……。」

¹⁶⁷ Vgl. Jauernig/Hess (Fn. 1), § 63 Rn. 40.

C. 當事人以外之人

當事人以外之第三人因未參與訴訟程序，提出攻擊防禦方法以維護其權利，為維護其訴訟權及其他基本權，原則上不受確定判決效力所及。然而，在某些特定案件，為避免經法院判決確定之訴訟標的一再重複被起訴，請求法院判決，不但導致訴訟資源浪費，而且可能導致裁判歧異，影響司法威信，造成當事人間權利義務關係混亂，因此，此等案件之判決，其確定力應擴張及於當事人以外之第三人。實務及通說之見解皆認為，形成判決原則上具有對世效力，因此，經由法院確定判決所創設、變更或消滅之法律關係不但對當事人生拘束效力，原則上並應對第三人生效¹⁶⁸。特別是撤銷訴訟屬於形成訴訟之典型，於原告勝訴，法院將法律關係撤銷或變更時，其判決之效力具有對世性。

此外，於類似必要共同訴訟之情形，因不要求有訴訟實施權之人應全體一同起訴或應訴，且因法院審判之訴訟標的對類似必要共同訴訟乃是同一，而應合一確定，若有訴訟實施權之人（得為類似必要共同訴訟人之人）未共同作為當事人，實體判決之確定力自應擴張及於彼等，以免於共同訴訟人非因個人事由敗訴時，其他人又重複起訴，規避合一確定之要求¹⁶⁹。

最後，依本法第216條第1項之規定，撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力¹⁷⁰。對於行政機關而言，若和解之內容為當事人之行政機關應撤銷或變更原行政處分或訴願決定者，在未撤銷或變更原行政處分以前，理論上該和解契約並無法拘束其他關係機關之效力。但如受理訴願機關為被告所締結

168 變更債權關係之形成判決，例外不具對世效，例如民法第74條關於暴利行為所生法律關係之調整。同說，陳計男（註129），頁83。

169 此為多數說，例如許士宦，民事訴訟法（上冊），頁449（2016年）。

170 拙見認為訴訟和解之效力準用本條之規定，似乎仍有商榷之處。

之和解契約，係以撤銷或變更原行政處分為內容者，應認為原處分機關受該和解契約之拘束而有撤銷或變更原行政處分之義務。此外，縱使訴訟和解以行政機關應撤銷或變更原行政處分或訴願決定為內容，其亦無拘束第三人之效力¹⁷¹。

（4）實質確定力之基準時

由於實質確定力產生之一事不再理原則，禁止判決確定之訴訟標的再度被實質審理判決，因而延伸產生所謂之失權效，詳言之，凡是當事人在前訴訟程序中可能提出而未提出之攻擊防禦方法，在該判決確定後，縱使當事人間提起第二訴，然不准其提出前訴得提出而未提出之攻擊防禦方法，避免當事人藉此方式於後判決否定前判決之確定力¹⁷²。當事人於前訴訟對於該攻擊防禦方法之存在或得提出是否認知並非重要¹⁷³。依實務、通說之見解，實質確定力之基準時係以事實審法院最後之言詞辯論終結作為判斷時點¹⁷⁴。此從強制執行法第14條可導出，其規定：「I. 執行名義成立後，如有消滅或妨礙債權人請求之事由發生，債務人得於強制執行程序終結前，向執行法院對債權人提起異議之訴。如以裁判為執行名義時，其為

171 最高法院71年台上字第1009號民事判例：「上訴人間成立之訴訟上和解，與確定判決有同一之效力，亦兼有私法上和解之性質，惟於法不能拘束非當事人之被上訴人。被上訴人係行使民法第244條第2項規定之撤銷權，請求撤銷上訴人間因和解所成立之代償契約行為，與民事訴訟法第380條第2項之規定，毫無相涉。不得謂其未具備民事訴訟法上開規定有關當事人請求繼續審判之原因而指其起訴為不合法。」

172 Vgl. *Jauernig/Hess* (Fn. 1), § 62 Rn. 22; *Völzmann-Stickelbrock* (Fn. 107), § 322 Rn. 42.

173 Vgl. *Jauernig/Hess* (Fn. 1), § 62 Rn. 22. 但當事人不知情可能構成再審之訴之事由，例如民事訴訟法第496條第1項第13款規定：「有下列各款情形之一者，得以再審之訴對於確定終局判決聲明不服。但當事人已依上訴主張其事由或知其事由而不為主張者，不在此限：……十三、當事人發現未經斟酌之證物或得使用該證物者。但以如經斟酌可受較有利益之裁判者為限。」

174 Vgl. *Rainer Hüßtege*, in: *Thomas/Putzo* (Hrsg.), *Zivilprozeßordnung*, 32. Aufl., 2011, § 32 Rn. 35; *Jauernig/Hess* (Fn. 1), § 63 Rn. 43; *Völzmann-Stickelbrock* (Fn. 107), § 322 Rn. 42; BGH, NJW 1985, S. 2825.

異議原因之事實發生在前訴訟言詞辯論終結後者，亦得主張之。II. 執行名義無確定判決同一之效力者，於執行名義成立前，如有債權不成立或消滅或妨礙債權人請求之事由發生，債務人亦得於強制執行程序終結前提起異議之訴。III. 依前二項規定起訴，如有多數得主張之異議原因事實，應一併主張之。其未一併主張者，不得再行提起異議之訴。」(粗體字為本文所強調)

判決確定基準時以前所有當事人可行使之攻擊、防禦方法，於判決確定後，當事人於隨後之其他訴訟喪失提出之權利，學理上稱為失權效(Präklusion)，亦有學者稱為遮斷效果(但不妨礙作為訴訟標的另提獨立訴訟)。我國多數見解認為撤銷權、解除權於事實審法院最後言詞辯論終結前若無不適主張之情形，判決確定後不得再主張¹⁷⁵。但拙見持保留態度。

最後，若判決基礎之個別事實(Tatsache)於最後事實審言詞辯論終結後發生變化，或發生個別新事實，由於後發生新事實或個別事實變更並未經原審審酌，不受確定效力所及，故當事人仍得提起新訴主張此事實。

3. 訴訟和解如何準用判決確定力？

由於訴訟和解之效力係準用判決之確定力，然而準用並非適用，故須探討「準確定判決」究竟具有何種效力？茲論述如下：

(1) 形式確定力？

如前所述，若當事人對於裁判已無法依通常之救濟程序(上訴、抗告或異議)請求將之廢棄時，該裁判即發生形式確定力，此種通常救濟程序常設有失權性質之救濟期間(不變期間)¹⁷⁶。若無

¹⁷⁵ 陳計男(註129)，頁61。

¹⁷⁶ Vgl. Seiler (Fn. 40), § 705 Rn. 1a.

救濟程序之裁判，一經作成即發生形式確定力，例如終審法院之判決。訴訟和解成立後，是否具有形式確定力，文獻上有認為訴訟和解成立後，當事人除依法得聲請繼續審判外，既不得依上訴或抗告方法聲明不服，即具有形式確定力¹⁷⁷。然而，拙見認為此見解並非無疑。由於訴訟和解係當事人兩造針對訴訟標的所締結之契約，並非法院之裁判，本質上並不存在救濟程序，而有對之表示不服進而請求法院廢棄、變更之可能，是以不應認為具有形式確定力，縱使法律規定訴訟和解具有準確定判決之效力，仍不能變更其本質。當事人無法對訴訟和解提起上訴或抗告，係因其契約本質（拘束當事人雙方）使然。至於和解有無效或得撤銷之原因，當事人本得依法律規定主張¹⁷⁸或行使其權利或依本法第223條以下之規定，請求繼續審判¹⁷⁹。有疑義者乃是請求繼續審判之不變期間經過後，當事人是否仍得主張訴訟和解無效或行使撤銷權，並向法院起訴？文獻上有認為，和解契約若有無效或得撤銷之原因，當事人本得隨時依法

177 參見王甲乙、楊建華、鄭健才，民事訴訟法新論，頁497（2008年）；姚瑞光，民事訴訟法論，頁465（2000年）；陳計男（註129），頁121；姜世明（註129），頁247。

178 類似見解參見司法院（72）廳民一字第0236號（民事法律問題研究彙編第3輯399頁）法律問題：訴訟上和解成立後，若有私法上得解除之原因發生，可否行使民法上之法定解除權解除之？討論意見：甲說：民事訴訟法第380條第1項規定和解成立者，與確定判決有同一之效力，確定判決既不得解除，訴訟上之和解自亦無從由當事人解除之。乙說：訴訟上之和解，一方面為私法行為，一方面為訴訟行為，不得僅著眼於其訴訟行為之一面謂可聲請強制執行而排除私法上所定解除權之行使，故如有上開原因發生，自可行使法定解除權解除之。結論：多數採甲說。司法院第二廳研究意見：訴訟上之和解在法律上之性質，一方面為公法上之訴訟行為，另一方面為私法上之法律行為。其在訴訟上，當事人既可以無效或得撤銷之原因請求繼續審判；在實體上於有給付不能等情事時，自亦可依法行使解除權。本題結論應採乙說。

179 參見最高法院43年台上字第1075號民事判例：「訴訟上之和解，為私法上之法律行為，同時亦為訴訟法上之訴訟行為，即一面以就私法上之法律關係止息爭執為目的，而生私法上效果之法律行為，一面又以終結訴訟或訴訟之某爭點為目的，而生訴訟法上效果之訴訟行為，兩者之間，實有合一不可分離之關係，故其行為如有私法上或訴訟法上無效或得撤銷之事由存在，不問何者，均屬民事訴訟法第380條第2項所謂和解有無效或得撤銷之原因，當事人自得以之為請求繼續審判之理由。」

主張或行使其權利，不應以訴訟法三十日不變期間之規定剝奪其權利。換言之，縱使請求繼續審判之不變期間已經過，當事人仍可主張，於執行程序，債務人得以此為由聲明異議，執行法院亦得以執行名義無效或已不存在而駁回強制執行之聲請¹⁸⁰。拙見認為此說可採，蓋若契約有無效之事由，應屬自始無效、當然無效、絕對無效，當事人應可隨時主張之¹⁸¹，若實體和解契約無效，則訴訟和解契約亦應無效；反之，若實體和解契約有效，而訴訟和解契約無效，則根本不成立訴訟和解，自難以逾越三十日之不變期間為由，剝奪當事人之權利¹⁸²。若和解契約有得撤銷之事由存在，依相同之理，亦應許當事人在實體法要件下行使。於此情形，當事人若因此提起新訴，應認為本法第107條第1項第9款之適用應限縮適用，不應包含此情形，而駁回其訴。

當然，當事人於給付訴訟或確認訴訟成立訴訟和解者，若無確定判決或準確定判決之效力，從訴訟法理上觀察，當事人應可對和解所生之新權利義務關係再度起訴爭執¹⁸³，然而，若和解不具有法

180 參見王甲乙、楊建華、鄭健才（註177），頁500；陳計男（註129），頁122-123。

181 相同見解參見最高法院78年度台上字第417號民事判決：「經法院核定之民事調解，依鄉鎮市調解條例第24條第2項規定，固與民事確定判決有同一之效力，然此項調解亦屬法律行為之一種，如其有民法上無效之原因，而當事人未依鄉鎮市調解條例第26條第2項規定，於法院核定之調解書送達後三十日內提起宣告調解無效之訴者，基於無效之法律行為係當然的、確定的、絕對的無效之法理，應解為不因該不變期間之經過而成為有效，故當事人仍得主張其為無效。」同院55年台上字第2745號民事判例則認為：「訴訟之和解成立者，依民事訴訟法第380條第1項規定，固與確定判決有同一之效力，惟此項和解亦屬法律行為之一種，如其內容違反強制或禁止之規定者，依民法第71條前段之規定仍屬無效。」然而實務亦有與此歧異之見解，例如最高法院46年台上字第1439號民事判例認為：「訴訟上之和解，一經成立，即與確定判決有同一之效力，故此項和解有無效之原因者，當事人僅得於三十日之不變期間內，聲請繼續審判，並非當然無效，此觀民事訴訟法第380條第2項之規定自明。」此見解拙見不採之。

182 同說，姚瑞光（註177），頁470。

183 Vgl. Eyermann/Geiger (Fn. 11), § 106 Rn. 34.

定聲請繼續審理之事由，立法者禁止當事人和其繼受人就已和解之事項（不論新舊法律關係）再度起訴爭執，若從終局解決當事人爭議之功能觀察，應亦可接受，惟此和形式確定力應屬無關。

（2）實質確定力？

自有民事訴訟法以來，我國實務一向認為和解成立者，就該訴訟標的發生一事不再理之效力，甚至在民國19年之民事訴訟法制定前，最高法院即採一事不再理之見解，例如17年上字第4號民事判例認為：「審判上之和解，一經合法成立，其訴訟即歸於消滅，非證明和解本身有無效或得撤銷之原因，當事人自應絕對受和解之拘束，縱令事後發見可受利益裁判之證據，亦不得就同一事件更行主張」¹⁸⁴（粗體字為本文所強調），而依民國19年之民事訴訟法第372條規定，訴訟和解成立者，當事人不得就該法律關係，更行起訴。依當時之立法理由，係著重於同一訴訟標的既經和解，事後即不得更行起訴，藉以貫徹保護私權之實，並減少法院負擔。雖說該規定重在一事不再理，但似缺乏充分論據認定當時之立法者就實質確定力係採取或趨向訴訟法說之新說。

再依比較法觀察，日本民事訴訟法第267條雖規定和解與確定判決具有同一效力，且文獻上有認為訴訟和解應具有既判力之見解，然而該國之有力學者，例如三ヶ月章、新堂幸司等認為訴訟和解係當事人間之私人行為，不應具有既判力。折衷說則認為，若訴訟和解有無效之原因時，即不具既判力，若無此等原因，則應具有既判力¹⁸⁵。

¹⁸⁴ 相同見解，最高法院17年上字第66號民事判例：「審判上之和解，一經合法成立，該訴訟即完全了結，縱使當事人一造受有不利益之結果，亦不能就和解之法律關係更行主張。」最高法院23年上字第899號民事判例亦同此旨。

¹⁸⁵ 參見陳計男（註129），頁122；三ヶ月章著，汪一凡譯，黃榮坤校訂，日本民事訴訟法，頁506（1997年）。

我國文獻上雖有主張既判力否定說者¹⁸⁶，惟通說認為，就和解標的之法律關係，當事人不得為相反之主張，法院亦不得於他訴訟為相異之判斷，此種拘束雙方當事人以及法院之效力，即為實質確定力（既判力）¹⁸⁷。拙見認為，立法者雖有權決定訴訟和解應具有之效力，但不應違背事物本質，詳言之，訴訟和解既屬於當事人之契約，縱使法律明文規定其「準確定判決之效力」，其效力仍應受契約本質限制，而非完全與法院之判決相同，是以應認為「準確定判決之效力」實際上係「準實質確定力」，因此，並非如判決般，須先具形式確定力後始生實質確定力。在行政訴訟法之立法有別於民事訴訟法，前者之訴訟和解並非具有與確定判決相同之效力，而是僅於性質相同之處，得準用確定判決之效力。從契約理論而言，行政訴訟法關於和解之立法優於民事訴訟法。

依實質確定力之訴訟法說之主張，確定判決之效力僅及於當事人，原則上既不及於第三人，則具有對世效力之權利，例如所有權、繼承權等等，縱使因錯誤判決認定不存在，該權利亦不消滅，反之，無權之人縱使因錯誤判決誤認為權利人，其亦不能向第三人主張權利，從而，具有準實質確定力之訴訟和解，其效力亦應限於此範圍，亦即縱使原告起訴之訴訟標的屬於絕對（對世）權，不論在給付訴訟抑或確認訴訟，其與被告之和解亦不生對世效力¹⁸⁸。故最高法院61年台再186號民事判例認為訴訟標的為物權者，該判決具有對世效力之見解，即不能適用於訴訟和解。更確切而言，訴訟

186 例如魏大曉（註26），頁221。

187 參見王甲乙、楊建華、鄭健才（註177），頁497；姜世明（註129），頁247。

188 此應是通說。參見王甲乙、楊建華、鄭健才（註177），頁497；最高法院71年台上字第1009號民事判例：上訴人間成立之訴訟上和解，與確定判決有同一之效力，亦兼有私法上和解之性質，惟於法不能拘束非當事人之被上訴人。被上訴人係行使民法第244條第2項規定之撤銷權，請求撤銷上訴人間因和解所成立之代價契約行為，與民事訴訟法第380條第2項之規定，毫無相涉。不得謂其未具備民事訴訟法上開規定有關當事人請求繼續審判之原因而指其起訴為不合法。

和解之效力僅存在於當事人就和解契約所生之權利義務，於當事人（或其繼受人）之間不得再起訴爭執，於確認訴訟之和解，就和解所生之權利義務發生確認力，而於給付訴訟，和解內容適於強制執行者，該和解得為執行名義而具有執行力，得據以聲請強制執行。就此，立法者為避免爭議，特於本法第305條第4項和強制執行法第4條第1項第3款明文規定，訴訟和解係單獨之執行名義，而非適用第305條第1項或強制執行法第4條第1項第1款之確定終局判決，由於立法者對於確定判決和訴訟和解仍區別規定，因此兩者之本質差異並不因準用而抹除。

伍、結語

訴訟和解做為由當事人自主協議、平和解決爭訟事件之手段，固然有其功能，且早已是民事訴訟重要之紛爭解決制度，然而，由於行政訴訟涉及依法行政和公共利益之維護，本質上與民事訴訟有其差異，是否允許訴訟和解早期一直存有爭議，德國直至1990年始在行政法院法增設此制度，我國雖參考德國法制亦設有此制度，但適用上仍應謹慎，避免違背法律，或妨礙公共利益。至於和解應有之效力，亦應注意其和判決之性質差異而為解釋，不應誤解為全然與確定判決效力相同。

參考文獻

1. 中文部分

- 三ヶ月章著，汪一凡譯，黃榮坤校訂（1997），日本民事訴訟法，臺北：五南。[三ヶ月章（1979），民事訴訟法，東京：弘文堂。]
- 王甲乙、楊建華、鄭健才（2008），民事訴訟法新論，臺北：三民。
- 吳庚（2015），行政法之理論與實用，增訂13版，臺北：自版。
- 林明鏘（2000），行政契約，收於：翁岳生編，行政法（下冊），2版，頁631-675，臺北：翰蘆。
- 姜世明（2016），民事訴訟法（下冊），修訂4版，臺北：新學林。
- 姚瑞光（2000），民事訴訟法論，臺北：自版。
- 徐瑞晃（2002），行政訴訟撤銷之訴在訴訟上之和解，收於：台灣行政法學會編，行政契約與新行政法，頁319-344，臺北：元照。
- 張文郁（2008），權利與救濟（二）——實體與程序之關聯，臺北：元照。
- 盛子龍（2005），當事人對訴訟標的之處分權作為行政訴訟上和解之容許性要件，台灣本土法學雜誌，71期，頁53-62。
- 許士宦（2016），民事訴訟法（上冊），臺北：新學林。
- 陳計男（2000），行政訴訟法釋論，臺北：三民。
- （2005），民事訴訟法論（下冊），增訂3版，臺北：三民。
- 陳敏（2013），行政法總論，8版，臺北，自版。
- 陳清秀（1991），稅務訴訟之理論與實務，臺北：三民。
- （2014），稅法總論，8版，臺北：元照。
- （2018），行政訴訟法，8版，臺北：元照。

陳榮宗（1984），民事程序法與訴訟標的理論，再版，臺北：國立臺灣大學。

陳榮宗、林慶苗（2005），民事訴訟法（中冊），修訂4版，臺北：三民。

——（2009），民事訴訟法（上冊），修訂6版，臺北：三民。

黃茂榮（2004），論訴訟標的，植根雜誌，20卷1期，頁1-25。

葉百修、吳綺雲（1990），行政撤銷訴訟之研究，臺北：司法院。

葉百修、張宏誠（2018），和解 § 219，收於：翁岳生、許宗力、張登科編，行政訴訟法逐條釋義，2版，頁595-620，臺北：五南。

蔡志方（2001），行政救濟法新論，臺北：元照。

魏大曉（2015），民事訴訟法，臺北：三民。

2. 外文部分

Arens, Peter/Lüke, Wolfgang (1999), Zivilprozeßrecht, 7. Aufl., München: C. H. Beck.

Barbey, Günther (1985), Bemerkungen zum Streitgegenstand im Verwaltungsprozeß, in: Hans-Uwe (Hrsg.), System des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes: Festschrift für Christian-Friedrich Menger zum 70. Geburtstag, Köln: Heymann, S. 177-189.

Bartone, Roberto (2008), in: Kühn/von Wedelstädt (Hrsg.), Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung, 19. Aufl., Stuttgart: Schäffer-Poeschel, FGO § 65.

Bittner, Dietmar (1998), Finanzgerichtsordnung, Stand: Lfg. 1998, Köln: Luchterhand, § 65.

Bonk, Heinz Joachim (2018), in: Stelkens/Bonk/Sachs (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz, 9. Aufl., München: C. H. Beck, § 55.

Brandis, Peter (2001), in: Tipke/Kruse (Hrsg.), Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, Stand: Lfg. März 2001, Köln: Otto

Schmidt, § 65.

Böhm, Peter (1986), Die Ausrichtung des Streitgegenstandes am Rechtsschutzziel, in: Rechberger/Welser (Hrsg.), Festschrift für Winfried Kralik zum 65. Geburtstag: Verfahrensrecht – Privatrecht, Wien: MANZ Verlag, S. 83-123.

Detterbeck, Steffen (1995), Streitgegenstand und Entscheidungswirkungen im Öffentlichen Recht, Tübingen: Mohr Siebeck.

Geiger, Harald (2000), in: Eyermann/Fröhler (Hrsg.), Verwaltungsgerichtsordnung, 11. Aufl., München: C. H. Beck, § 106.

Gottwald, Peter (2000), in: Rauscher/Krüger (Hrsg.), Münchener Kommentar ZPO, Bd. 1, 2. Aufl., München: C. H. Beck, § 322.

——— (2013), in: Rauscher/Krüger (Hrsg.), Münchener Kommentar ZPO, Bd. I, 4. Aufl., München: C. H. Beck, § 322.

Grunsky, Wolfgang (1974), Grundlagen des Verfahrensrechts, 2. Aufl., Bielefeld: Giesecking.

Gräber, Fritz (2006), in: Groll/Koch/Ruban/Stapperfend (Hrsg.), Finanzgerichtsordnung, 6. Aufl., München: C. H. Beck, § 65.

Habscheid, Walther Jakob (1990), Die neuere Entwicklung der Lehre vom Streitgegenstand im Zivilprozeß, in: Gottwald (Hrsg.), Festschrift für Karl Heinz Schwab zum 70. Geburtstag, München: C. H. Beck, S. 181-195.

Hartmann, Peter (2014), in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann (Hrsg.), Zivilprozessordnung, 72. Aufl., München: C. H. Beck, § 322.

Henckel, Wolfram (1992), Stein/Jonas – ein Großkommentar zur Zivilprozeßordnung, JZ, S. 645-656.

Hüßtege, Rainer (2011), Thomas/Putzo (Hrsg.), Zivilprozeßordnung, 32.

- Aufl., München: C. H. Beck, § 32.
- Jauernig, Othmar (1967), Verhandlungsmaxime, Inquisitionsmaxime und Streitgegenstand, Tübingen: Mohr.
- (1998), Zivilprozeßrecht, 25. Aufl., München: C. H. Beck.
- Jauernig, Othmar/Hess, Burkhard (2011), Zivilprozessrecht, 30. Aufl., München: C. H. Beck.
- Kopp, Ferdinand Otto/Ramsauer, Ulrich (2000), Verwaltungsverfahrensgesetz, 7. Aufl., München: C. H. Beck.
- Kothe, Peter (2010), in: Redeker/von Oertzen (Hrsg.), Verwaltungsgerichtsordnung, 15. Überarbeitete Aufl., Stuttgart: Kohlhammer, § 106.
- Lammerding, Jo (2005), Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung und Nebengesetze, 15. Aufl., Achim: Erich Fleischer.
- Lerche, Peter (1956), Zum Stand der Lehre vom Streitgegenstand im Verwaltungsprozeß, BayVBl, S. 295-299.
- Lüke, Gerhard (2002), in: Krüger/Rauscher (Hrsg.), Münchener Kommentar ZPO, 2. Aufl., München: C. H. Beck, §§ 253, 264.
- Musielak, Hans-Joachim (1991), Grundkurs ZPO, München: C. H. Beck.
- (1995), Grundkurs ZPO, 3. Aufl., München: C. H. Beck.
- Niese, Werner (1952), Über den Streitgegenstand der Anfechtungs- und Vornahmeklagen im Verwaltungsprozeß, JZ, S. 353-358.
- Redeker, Konrad (1992), Anmerkung zum Urteil des BVerwG vom 24.01.1992 – 7 C 24.91, DVBl, S. 1225-1226.
- Rennert, Klaus (2000), in: Eyermann/Fröhler (Hrsg.), Verwaltungsgerichtsordnung, 11. Aufl., München: C. H. Beck, § 121.
- Rosenberg, Leo/Schwab, Karl Heinz/Gottwald, Peter (1993), Zivilprozeßrecht, 15. Aufl., München: C. H. Beck.

- (2007), Zivilprozeßrecht, 16. Aufl., München: C. H. Beck.
- Schallmoser, Ulrich (2008), in: Hübschmann/Hepp/Spitaler (Hrsg.), Abgabenordnung/Finanzgerichtsordnung, Stand: Lfg. 2008, Köln: Otto Schmidt, FGO § 65.
- Schenke, Wolf-Rüdiger (2014), in: Kopp/Schenke (Hrsg.), Verwaltungsgerichtsordnung, 20. Aufl., München: C. H. Beck, §§ 82, 90, 106.
- Schroeder-Printzen, Jörn (1990), Die Beschwer des beigeladenen Sozialleistungsträgers über §§ 102 ff. SGB X - Zugleich ein Beitrag zu Problemen der Beiladung, NVwZ, S. 614-620.
- Schumann, Ekkehard (1984), in: Stein/Jonas (Hrsg.), Kommentar zur ZPO, Bd. 1, 20. Aufl., München: C. H. Beck, Einleitung.
- Seiler, Christian (2011), in: Thomas/Putzo (Hrsg.), Zivilprozeßordnung, 32. Aufl., München: C. H. Beck, Einleitung II, §§ 253, 322, 704, 794.
- Ule, Carl Hermann (1987), Verwaltungsprozeßrecht, 9. Aufl., München: C. H. Beck.
- Völzmann-Stickelbrock, Barbara (2011), in: Prütting/Gehrlein (Hrsg.), ZPO, 3. Aufl., Köln: Luchterhand, § 322.
- Wolff, Hans Julius/Bachof, Otto/Stober, Rolf (2001), Verwaltungsverfahrensgesetz, 6. Aufl., München: C. H. Beck.
- Zöller, Richard (1993), Zivilprozeßordnung, 18. Aufl., Köln: Otto Schmidt.